



Sommaire :

Introduction :

I – La définition de la famille

A – la complexité de la notion de famille

B – Les diversités des liens familiaux pris en compte par le droit

1/ Transformation des liens familiaux traditionnels

a) Le lien de parenté

b) Le lien d'alliance

2/ Nouveaux liens qui ont fait l'objet de consécration

II – L'évolution du droit de la famille et de ses sources

A – L'évolution historique du droit de la famille

B – Evolution des sources du droit de la famille

1/ Les sources internes

2/ Les sources internationales

Partie 1 : Le droit de la famille relatif aux couples

I – Les couples mariés

A – Le principe de la liberté matrimoniale

1/ Les clauses de contrats et le courtage de mariage

2/ Les fiançailles

B – La formation du mariage

1/ Conditions de formation du mariage

a) Biologiques

b) Sociologiques

c) Psychologiques

d) Forme

2/ Les sanctions de condition de formation du mariage

° Les oppositions au mariage

° L'annulation

° Les effets de la nullité

C – Les effets du mariage

1/ Les effets personnels

a) Les devoirs imposés aux deux époux pour la direction de la famille

b) Les devoirs réciproques entre les époux

c) Les autres obligations des époux

2/ Les effets patrimoniaux du mariage

a) L'autonomie de chaque époux

b) La sauvegarde des intérêts en matière patrimoniale

c) Le régime matrimonial

D – Les effets du divorce

1/ Divorce par consentement mutuel

a) Le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes du notaire

- b) Le divorce par consentement mutuel judiciaire
- 2/ Les divorces contentieux
 - a) Présentation des divorces contentieux
 - b) Procédure commune aux divorces contentieux
- 3/ Les effets du divorce
 - a) Les effets personnels du divorce
 - b) Les effets patrimoniaux du divorce

II – Les couples non mariés

A – Le pacte civil de solidarité

- 1/ La formation du PACS
 - a) Les conditions de fond
 - b) Les conditions de forme
- 2/ Les effets du PACS
 - a) Les effets d'ordre personnels du PACS
 - b) Droits et obligations patrimoniaux
- 3/ La dissolution du PACS
 - a) Les causes de la dissolution
 - b) Les conséquences de la dissolution du PACS

B – Le concubinage

- 1/ La définition du concubinage
 - a) Le concubinage comme union de faits
 - b) Une union de couple
- 2/ Les effets de droit qui naissent du concubinage
- 3/ La rupture du concubinage

Partie 2 : Le droit de la famille relatif aux enfants

I – Les règles relatives à la filiation

A – La filiation par procréation naturelle

- 1/ L'établissement non contentieux de la filiation
 - a) Etablissement de la filiation par les faits de la loi
 - b) Etablissement de la filiation par la reconnaissance volontaire
 - c) Etablissement du lien de filiation par la possession d'état
- 2/ L'établissement contentieux du lien de filiation
 - a) Les actions en recherche de filiation
 - b) Action en contestation du lien de filiation
 - c) Les effets de la contestation de la filiation

B – La filiation adoptive

- 1/ Les conditions similaires des adoptions

Droit civil : la famille

Introduction :

Il constitue l'une des branches du droit civil. En droit de la famille nous étudierons des règles qui **ne concernent que les personnes physiques**. Il se distingue également du droit public qui régit les relations entre les personnes privées et l'Etat, organisations etc.

Le droit civil se compose également du droit des biens, droit des contrats et des matières qui touchent à la famille, que nous étudierons plus tard, tels que le droit des régimes matrimoniaux ou le droit successoral.

Parmi l'ensemble des matières, le **droit de la famille porte sur l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les membres de la famille**.

Mais alors comment définir la famille ?

I- La définition de la famille

Dans le langage courant, la famille renvoie à un **groupe de personnes physiques**, généralement constitué par un couple de parents, de leurs enfants, et plus largement par un ensemble d'individus qui y sont apparentés, par le mariage ou par le sang, parce qu'ils **descendent d'ancêtres communs**. La famille c'est une **cellule sociale**, la cellule par excellence, la première d'entre elles. La famille est la **première instance de socialisation** dans laquelle se développe l'individu.

Mais il est difficile de déterminer avec précision quelles sont les frontières exactes du groupe familial, des liens familiaux.

Dans **certains pays**, (nordiques notamment), la famille renvoie à une **conception restreinte**, nucléaire (le noyau), c'est à dire les **parents et l'enfant**. Dans d'autres pays, la famille sera perçue au sens plus large, comme le **modèle méditerranéen** dans lequel les membres de la famille s'étend au delà du lien parents enfants, et **unit les différentes générations**.

La **famille ne fait l'objet d'aucune définition au sein du code civil**.

Pour autant, on s'aperçoit que le **droit civil traduit une certaine vision de ce qu'est la famille**, tout en évoquant d'avantage les différents liens qui peuvent unir les personnes au sein de cette cellule que l'on appelle la famille. En d'autre terme, le droit français de la famille s'intéresse aux **liens intra-familiaux** plutôt qu'au groupe familial en lui même.

A- La complexité de la notion de famille

La famille est conçue comme une **notion complexe**, pourtant en droit civil elle est une **notion essentielle**. Le **doyen Jean Carbonnier** expliquait que la famille constituait avec le contrat et la propriété, **l'un des trois piliers du droit**. Cependant, seule la famille n'est pas définie dans le CC. Mais la mention de la famille apparaît plusieurs fois dans le CC, comme dans le droit des personnes vulnérables, on fait référence au conseil de famille. De la même manière, le CC fait référence au nom de famille, ainsi que du logement familial.

* Mais alors qu'est ce que la famille ?

Pour constituer une famille il faut au minimum être 2. Mais où s'arrêtent les frontières de la famille ? Les **liens de parentés sont multiples** (grand oncle, compagnon non marié, etc). Ces contours sont mouvants, ils **changent selon le temps et les personnes considérées**. Ainsi, selon comment on considère, la famille ne sera pas perçue de la même manière. On parle souvent aujourd'hui « **des familles** », plutôt que de la famille. -> **Code de l'action sociale et des familles**, même le législateur emploie ce terme.

On va utiliser plusieurs qualificatifs : la famille nucléaire (le noyau), la famille traditionnelle (mari femme et enfants), la famille recomposée, les familles légitimes ou naturelles, les familles homoparentales, familles monoparentales.

=> Ce vocabulaire est issu des **sciences sociales**, en particulier de la sociologie, et non pas du domaine juridique. Ces études sociologiques sur la famille ont mis en évidence des évolutions des modèles familiaux qui sont à l'oeuvre au sein de nos sociétés modernes. **Toute définition de la cellule familiale est impossible car il y a en réalité plusieurs modèles familiaux**. La famille évolue, elle n'est pas figée. Elle **évolue en fonction du contexte social**. Il y a quelques décennies la famille était composée sur la base d'un union marital entre un homme et une femme ainsi que des enfants dont l'autorité revenait au père de famille.

Aujourd'hui, le modèle traditionnel de la famille fondé sur le mariage n'est **plus le seul modèle**, de plus en plus d'enfants naissent hors mariage, il y a de plus en plus de divorces.

Ces **transformations sociales emportent évidemment un certain nombre de conséquences**, notamment à travers la reconnaissance de formes d'union qui sont des unions alternatives au mariage. Par exemple, le juge aux affaires matrimoniales, qui composait autrefois la juridiction chargée de résoudre les problèmes au sein d'une famille a été renommé en juge aux affaires familiales, marquant ainsi l'étendue réelle de l'office du juge. -> traite de l'ensemble des problèmes familiaux qui naissent dans une famille non structurée.

Le droit ne prévoit pas une définition précise du concept de famille. Elle fait partie en droit de ce qu'on appelle les notions floues, ou les concepts flous, les notions indéterminées.

=> **Si la définition de la famille était extrêmement précise, le droit de la famille évoluerait difficilement.**

Il y a donc un avantage à ces notions floues, qui permettent aux juges d'interpréter le droit au gré des évolutions sociétales. Mais il réside des difficultés : comment prévoir la solution claire à un problème, il y a aussi des problèmes de qualifications juridiques et donc incertitudes quant à la solution à apporter.

Cela dit, le droit civil prend en compte la variété des liens familiaux qui unissent les personnes au sein du groupe familial

B- Les diversités des liens familiaux pris en compte par le droit

La famille contemporaine s'appuie sur des liens qui sont appréhendés par le droit. -> le lien conjugal ou encore le lien de filiation

Ils ont connus des évolutions : ces liens traditionnels ont connus des mutations, mais se pose aujourd'hui la question de la reconnaissance possible de nouveaux liens familiaux.

1/Transformation des liens familiaux traditionnels

Traditionnellement la famille repose sur 2 types de liens :

L'un est dit horizontal = lien d'alliance

L'autre est dit vertical = lien de parenté

a) Le lien de parenté

C'est un mot dont l'étymologie vient du latin « **parere** » qui signifie engendrer. Désignation du lien juridique qui permet d'intégrer l'enfant dans la famille de ses parents et qui l'inscrit dans une lignée généalogique. Cette lignée se décompose, car le lien de parenté découle de l'addition de plusieurs liens de filiation. Quand on évoque le terme de parents, en droit, on pense en premier lieu aux personnes qui donnent naissance à un enfant, mais juridiquement parlant, le terme désigne un lien qui repose sur une filiation qui existe entre les personnes dont l'une descend de l'autre, ou qui descendent d'un auteur commun.

En réalité il y a deux types de lien de parenté :

° **La parenté en ligne directe** = lien de parenté le plus facile à comprendre car est celle qui relie les ascendants et les descendants, le lien de parenté qui relie les personnes qui descendent les unes des autres Art 742 du CC, on fait référence aux arrière grands parents, grands parents, parents, enfants, petits enfants, etc.

Attention, la ligne directe peut être suivie dans un sens mais également dans l'autre → ligne descendante entre grand père et petit fils, mais ligne ascendante entre petits fils et grands parents.

° **La ligne collatérale** de parenté = Dans le cas de frères et de soeurs. On établit un lien de parenté entre les frères et soeurs, qui n'est pas établie dans le lignage direct. On relie les personnes qui sont issues d'un auteur commun. (fratries, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, etc). Art 741 et 745 du CC on retrouve les degrés d'éloignement « la proximité de parenté s'établit par nombre de génération, chaque génération s'appelle un degrés ». Un frère et une soeur ont un degrés de parenté plus proches que des cousins par exemple.

Ce degré de parenté est particulièrement utile en droit de la succession.

– En **ligne directe** on compte un degré par niveau (les parents sont le premier degré des enfants, les grands parents sont au deuxième degrés.).

– En **ligne collatérale** les choses se compliquent un peu. On compte, selon l'art 743 qui dispose qu'il faut remonter jusqu'au premier ancêtre commun puis redescendre. On compte le nombre de degrés qui sépare chaque intéressé de leur ancêtre commun et on les additionne. Par exemple un frère et une soeur sont parents au deuxième degrés.

b) Le lien d'alliance

Le mot vient du latin « **aliare** » qui signifie lier. Il signifie simplement le fait de lier un des époux à la famille de l'autre.

De cette alliance va résulter une série de droits et d'obligations, entre les époux mais également entre gendres et beaux parents.

Le lien de filiation a beaucoup évolué ces dernières années. Il désigne le lien qui uni des parents biologiques ou adoptifs avec leur enfant. Au départ, ce lien de filiation ne pouvait se présenter que sous deux types particuliers, soit le lien de filiation qui fait suite à la naissance d'un enfant, soit celui qui fait suite à une adoption.

Depuis le **début du 21e siècle le droit de la filiation a évolué** ; d'une part le droit de la filiation s'est adapté à la **diversification des modes de procréation** (notamment par l'instauration de la PMA), et d'autres part avec la **reconnaissance des couples de même sexe**, et ainsi la possibilité d'adopté un enfant par un couple de même sexe.

Ce lien d'alliance (le mariage), s'est retrouvé concurrencé de plus en plus par **d'autres modes de conjugalité**. Par exemple avec la création du PACS, ou lorsque le droit a été réformé dans le but de reconnaître des droits aux couples qui vivent dans des situations de concubinage.

2/ Nouveaux liens qui ont fait l'objet de consécration

Il existe de nouvelles possibilités de conjugalités reconnues par le droit au bénéfice de personnes qui ne sont pas mariés, ni parentes. Seul l'effectivité de leur relation sera prise en compte, typiquement le cas du concubinage.

Malgré la liberté que ces derniers veulent conserver, la **relation sera reconnue par le droit et pourra entraîner un certain nombre de reconnaissances juridiques**.

Cette reconnaissance du PACS ou du concubinage participe a une **libéralisation du droit** qui permet de mettre a disposition des individus d'autres modes d'organisation de leur vie de couple.

De nouveaux liens de parenté sont imaginés :

– Questions au sujets des liens reconnus aux beaux-parents (nouveaux conjoint du parents), et réfléchir au statut du beau-parent revient à concevoir une famille plus large que celle actuellement en vigueur.

=> La famille c'est à la fois une structure composée des multiples liens évoqués plus haut, mais également une structure dans laquelle les personnes qui sont ainsi liées entre elles entretiennent des relations dites « de familles », relations qui sont sources de droit et d'obligation. **Le droit de la famille c'est le droit qui s'intéresse aux structures familiales mais également aux relations familiales qui résultent de ces structures.**

II – L'évolution du droit de la famille et de ses sources

A – L'évolution historique du droit de la famille

Avant la période de la révolution le **droit de la famille était centré sur les liens de parenté**, surtout sur les liens de la famille dite « de souche », liens biologiques. Les règles appliquées au sein de la famille étaient imprégnées de la religion, le mariage était indissoluble.

Avec la Révolution française cette conception très patriarcale et religieuse a évolué. **La famille s'est détachée de la religion** et le **mariage va être rapproché de la notion de contrat**. On va considérer que le mariage est un contrat civil, et pourra donc être rompu par les parties.

En 1804, est rédigé le code civil, et le droit de la famille subit alors un net recul par rapport aux

avancées révolutionnaires. → revalorisation de la famille légitime, et on réaffirme la supériorité de l'enfant né dans les liens du mariage par rapport à celui né hors mariage.

De plus, la femme est considérée comme une personne incapable, qui n'a pas la capacité de contracter et doit donc être représentée par son mari ou son père.

A partir du 20e siècle jusqu'aux années 1960, l'Etat a pris une part accrue dans la vie familiale, notamment en prenant en charge la protection de l'enfant et de la famille (allocations familiales, éducation, assistance éducative etc). C'est à cette époque que le droit favorise la famille nucléaire par rapport aux autres membres de la famille. Le conjoint et les enfants ont plus d'importance que les autres membres.

Un certain équilibre commence à s'établir, notamment pour les femmes, qui acquièrent un droit sur leur biens.

Depuis les années 60 le code civil a fait l'objet de 2 séries de réformes de grandes envergures :

* **1965 / 1975** : réformes conduites sous la direction du Doyen Carbonnier. → l'évolution de la société dans laquelle il vit est particulièrement rapide (30 glorieuses, essor de l'individualisme etc), **grande attention portée au bonheur et la liberté individuelle** : il souhaite mettre en place un droit de la famille plus souple. Il consacre l'égalité entre les membres du couple, l'égalité dans la filiation, mise en avant de l'intérêt de l'enfant. Plusieurs lois peuvent être citées :

- 13 juillet 1965 : loi qui consacre l'égalité juridique entre les époux pour la gestion patrimoniale de leur bien
- 4 juillet 1970 : autorité parentale. Loi qui promouvait l'égalité entre les sexes, met fin à la puissance paternelle, et substitue l'autorité parentale qui est exercée par les 2 parents.
- 3 janvier 1972 : loi sur la filiation qui améliore la situation juridique de l'enfant naturel par rapport à l'enfant légitime.

* **Fin du 20e siècle** (1999) jusqu'à nos jours : permet de prendre en considération des évolutions importantes de la société (sociales, culturelles ou juridiques), marqué par **l'essor du concubinage et des naissances hors mariages + grande acceptation de l'homosexualité**.

- 5 novembre 1999 : création du Pacte Civil de solidarité (PACS) et permet une définition du concubinage.
- 3 décembre 2001 : alignement des droits de l'enfant naturel sur celui de l'enfant légitime.
- 4 mars 2002 : égalité réelle et totale entre le père et la mère quant à l'éducation des enfants
- 26 mai 2004 : simplification du divorce, le divorce par consentement mutuel
- Ordonnance 4 juillet 2005 : réforme le droit de la filiation et établissement d'un ensemble de règles qui visent à établir et contester la filiation à l'égard d'un enfant et ce, quelque soit la filiation juridique du parents (PACS, mariage etc)
- 4 avril 2006 : élévation de l'âge nuptial de la femme (de 15 à 18 ans).
- 23 juin 2006 : plus grande place à la volonté des individus en leur permettant par la voie testamentaire de léguer plus facilement aux personnes choisies, ainsi qu'au conjoint survivant.
- 7 mai 2013 : loi du mariage pour tous, ouverture du mariage et de l'adoption aux couples du même sexe.
- 18 novembre 2016 : favorise à nouveau les divorces par consentement mutuels, notamment par acte d'avocat (on ne passe plus forcément devant un juge).
- 23 mars 2019 : réforme en profondeur la procédure de divorce, pour tous les types de

divorces.

- 30 juillet 2020 : protection des victimes de violences conjugales
- 2 août 2021 : ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Ces différentes réformes **dessinent plusieurs lignes directrices**, le législateurs, au fil des années a transformé le droit de la famille en suivant plusieurs objectifs. Tels que la **recherche de l'égalité** (entre les membres de la familles, et entre les différentes formes de familles), ou encore la **consacration de la pluralité des modèles familiaux**. A cette diversité on peut ajouter la **poursuite de la liberté**, car le droit de la famille est poussé par un **mouvement de libéralisation**, de contractualisation du droit. On envisage les rapports familiaux de la même manière qu'on envisage les rapports entre co-contractants.

Enfin, on assiste à la **poursuite d'une meilleure protection de l'enfant**, de son statut et des ses intérêts.

CM2 : 23/01/2025

Evolution des sources des règles de droit : les textes et les institutions qui forment les règles ont aussi changé.

B- Evolution des sources du droit de la famille

Ces sources ont évolué car à l'origine, les sources du droit de la famille étaient dans le Code Civil. Mais aujourd'hui, les textes consacrés à la famille se trouvent également en dehors, non seulement le CC est pas le seul, mais de plus en plus de place faite au droit international.

1/ Les sources internes / franco-françaises

D'autres codes que le Code Civil consacrent des articles : **Code de la santé publique** (droit de la filiation par exemple, ou la PMA), dans le **Code de l'action sociale et des familles** (on y retrouve des règles et normes relatives au droit de la famille, comme l'accouchement sous x etc,) et plus largement dans d'autres branches telles que le **droit constitutionnel**, le **Code du commerce**, le **droit fiscal**, etc.

Le plus important ici étant le **droit pénal** : on y trouve bcp de règles spécifiques qui sanctionnent les atteintes aux mineurs et à la famille (**art 227-1 et suiv du CP**), on va y trouver les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, les sanctions relatives aux violences intra-familiales, etc.

2/ Les sources internationales

Se développent également depuis de nombreuses années des sources internationales, elles jouent un rôle de plus en plus important. Ces textes sont très nombreux, certains n'ont pas forcément de valeur juridique, mais d'autres sont essentiels.

Exemple de textes :

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (art 8 « la famille est l'élément fondamental de la société et a donc le droit à la protection de la société et de l'Etat »)
- Pacte International relatif aux droits civils et politiques (droit à la vie privée art 17, droit de se marier art 23, égalité des droits et des responsabilités entre époux art 23, et égalité des enfants art 24.
- Convention Internationale sur le droit de l'enfant (prévoit l'obligation pour l'Etat de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant art 3)
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (charte de Nice) du 7 décembre 2000 qui réaffirme le droit au respect de la vie privée et de la famille, égalité entre époux, droit au mariage, égalité entre enfants. -> charte uniquement applicable dans les pays de l'UE
- Convention Européenne des droits de l'homme qui a une incidence importante en droit français, car art 8 garantie droit à la vie privée et familiale comme droit fondamental, non seulement ces articles vont pouvoir être utilisés directement devant les juges internes, mais en plus, et de façon subsidiaire, en cas de violation de droit fondamental et lorsque les voies de recours sont épuisées, on peut saisir la CEDH qui peut condamner l'Etat coupable de la violation.

Partie 1 : Le droit de la famille relatif aux couples

Le **droit de la famille ne définit pas ce qu'est le couple** car on ne retrouve pas de définition dans Code Civil, mais ne veut pas dire qu'on peut pas essayer d'en donner une définition. → Cette notion de couple renvoie à un **lien reconnu par le droit, lien qui unit deux personnes qui ont la volonté durable de s'engager dans une vie commune.**

Deux distinctions :

I – Les couples mariés

Deux personnes qui s'unissent ne sont pas contraintes de se marier. Mais s'ils souhaitent se marier, il faut s'intéresser à la formation du mariage (comment ils s'unissent, etc). De plus, quels sont les effets du mariage, du point de vue personnel mais aussi patrimonial ? Et comment dissoudre le mariage ?

A – Le principe de liberté matrimoniale

Se marier est un droit et avant tout une liberté. En principe on ne peut être contraint, forcé, à se marier. Inversement, il ne peut exister d'interdiction à mariage. Ce droit au mariage est consacré par plusieurs textes : dans la **DUDH**, dans la **CEDH**, dans la **Charte des droits de l'Homme**.

Ce droit au mariage s'appelle la **liberté matrimoniale ou nuptiale**. En plus d'être reconnu dans ces textes, en droit interne, cette **liberté à une valeur constitutionnelle** (13 août 1993, le Conseil Constitutionnel indique que la liberté matrimoniale est une composante de la liberté individuelle constitutionnelle garantie). Il s'agit donc d'un **droit fondamental**. Question de savoir s'il est possible pour des futurs époux de renoncer par avance à leur mariage. Idem, peut-on s'engager par anticipation à ne jamais se marier ?

Questions qui font débat.

→ un couple qui décide de se fiancer, est ce qu'il est possible d'y renoncer ensuite.

→ Aussi, on retrouve également des clauses de célibats dans certains contrats, qui viennent restreindre le droit au mariage.

1/ Les clauses de contrats et le courtage de mariage

– Ces **clauses de célibats** (clause de non convol), sont **normalement condamnées par la garantie de droit matrimonial**. Ces clauses incluses dans des contrats qui interdisent le mariage sont en principe interdites. Cependant, un principe connaît toujours des exceptions. Il **existe des cas où ces clauses, vont, sous certaines conditions, être admises**. Par exemples dans des **contrats particuliers qui sont des contrats à titre gratuit** (donation). En contrepartie, aucune somme d'argent n'est versée à celui qui donne. Parfois, on va considérer que des clauses limitant la liberté matrimoniale du donataire pourront être valable **à condition** qu'elle ne suive pas un objectif ou ne soit pas inspiré par une volonté de nuire ou par une cause immorale ou répréhensibles. (donation dans le cas d'un héritage où il est stipulé dans le contrat que la personne ne pourra pas obtenir l'héritage si elle est mariée avec tel ou tel

personne, à telle ou telle date). Mais parfois noté pour des raisons de jalousie ou autre alors la clause du contrat sera déclarée irrecevable. (**Arrêt cour d'appel de Paris 8 mars 1824**)

Ces clauses **peuvent aussi empêcher les personnes mariées de divorcer** (clause de non-divorce). Elles sont normalement interdites sauf dans les actes à titre gratuit où elles bénéficient d'une autorisation de principe, là encore à la condition qu'elle ne soit pas inspiré par la volonté de nuire à la personne qui bénéficie de l'acte. (**Arrêt 13 dec 2005 première chambre civile cour n°02-14.135**)

– Les **contrats de courtage matrimonial** sont des contrats par lesquels un **professionnel** (un courtier) va **s'engager moyennement rémunération à mettre en relation certaines personnes afin de faciliter leur mariage**. Ce contrat est valable à condition de n'avoir pour seul objectif la mise en relation, rapprochement de candidats au mariage **sans que ces derniers n'aient ensuite l'obligation de se marier**.

2/ les fiançailles

Elles peuvent se définir comme la **promesse de se prendre plus tard pour pour époux**. Pour un grand nombre de personnes c'est l'étape qui précède le mariage. Les fiançailles se rapprochent d'une situation de vie de couple que l'on appelle le concubinage.

Historiquement, les fiançailles ont une place à part car avant, les fiançailles amenaient à établir un contrat. Aujourd'hui, **les fiançailles sont égales au concubinage**. → **pas de conséquences juridiques particulières**, et la **promesse de mariage n'est pas protégée**, elle peut être rompue à tout moment, ce n'est pas en soit fautif. Mais exceptions : dans certaines circonstances particulières où les fiançailles entraînent des conséquences juridiques. Par exemples :

– les fiançailles sont **rompues de manière abusives** (rupture abusive des fiançailles) : rupture réalisée dans des circonstances fautives. **Possible d'engager la responsabilité de l'auteur** de la rupture des fiançailles.

→ Le principe de responsabilité oblige quiconque qui a commis une faute de réparer les dommages, préjudices engendrés par cette faute.

Circonstances dans lesquelles la rupture est dite abusive

* **Cour d'app de Rouen 15 juin 2005** : future mariée et invités qui ont attendu le futur mari qui n'est pas venu le jour du mariage. → fiançailles rompues au dernier moment, de façon abrupte, sans donner d'explications. ⇒ les juges ont considéré que la faute est considérée et en raison du préjudice causé à la future mariée, les juges ont fait droit à la demande de réparation de la requérante, sur le fondement de **l'art 1240 du CC**.

– **Conséquences juridiques** : Le droit civil de la famille prévoit le **sort des cadeaux que les personnes se font à l'occasion des fiançailles**. **Art 1088 du CC**, « **toute donation faite en faveur du mariage sera caduc si le mariage ne s'ensuit pas** ». Ne concerne **que les donations d'une certaine valeur**. Les cadeaux d'usage (faible valeur, comme un bouquet de fleurs séchées), ne sont pas concernés par la règle. Difficulté pour déterminer la valeur importante ou pas du cadeau, idem pour les animaux. **La bague de fiançailles** elle, connaît un régime spécifique, dans tous les cas (bijoux de famille par exemple) elle devra être restituée. (**27 mars 2019 cour d'appel de Rennes**).

B – La formation du mariage

Le mariage est l'une des **plus anciennes coutumes de l'Humanité**, l'une des **plus universelles**. Le mariage est donc à la fois un **acte issu de volonté individuelle**, mais aussi un acte qui possède une **portée sociale** car reflète d'une certaine manière les conceptions sociales, culturelles, idéologiques, de notre société. La **formation du mariage va être soumise à un certain nombre de conditions particulières**. La vérification de ces conditions se fait en 2 temps, d'abord en **amont** (avant le mariage et pdt la cérémonie l'officier d'Etat civil va intervenir pour vérifier que les époux remplissent les conditions édictées par la loi), et **a posteriori** un contrôle qui va être mis en oeuvre pour s'assurer de la validité du mariage. Prend concrètement la forme de la possibilité d'annuler le mariage si celui-ci ne répond pas aux conditions de validités requises.

1/ Conditions de formation du mariage

Le choix de ces conditions est un **choix politique et idéologique** (il est diff selon les pays et varie même au sein des pays). En droit français : ces conditions sont classées en diff catégories :

– **Biologiques** → le sexe, l'âge, la santé.

– **Le sexe** : Les époux, aujourd'hui, n'ont **pas besoin de répondre à des critères liés au sexe** : **art 143**, de la loi du 17 mai 2013 « **le mariage est contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe** ». Cependant, cette loi de 2013 a bouleversé la conception initiale du mariage. Avant, le mariage était **corrélé avec la reproduction et la parenté**. En détachant le mariage de cette fonction reproductive, le **législateur détache le mariage de la parenté**. Dorénavant, on **donne de l'importance aux couples mariés qui ne veulent pas d'enfants**.

– **L'âge** : Pour pouvoir se marier il **faut remplir une condition d'âge minimum**. Jusqu'à la loi du 4 avril 2006, l'âge minimum était différent selon les hommes (18 ans) et les femmes (15 ans). Désormais, **l'âge nuptial est à 18 ans sans distinction selon le sexe**. **Art 144 du CC**.

Cependant, il y a des exceptions **art 145 CC** → loisible au **Procureur de la République d'accorder des dispenses pour motifs graves**. Le mariage d'un mineur est possible à deux conditions : il faut **justifier de motif grave** (ex : jeune fille mineure (de +15 ans) qui veut se marier avant d'accoucher), le mineur doit **recevoir le consentement de ses parents** ou, si ses parents ne sont pas en mesure, par d'autres personnes tels que des proches. Cet accord est imposé par **l'art 148** « **les mineurs ne peuvent contracter mariage sans consentement de leur père et mère ou l'un d'eux** ». De plus, il n'y a **pas de limite d'âge max** pour se marier, **ni de conditions d'âge max entre les époux**. Le CC organise même des **mariages « in-extremis »**, de personne dont la mort est imminente. (sauf si la personne n'est plus en mesure d'exprimer son consentement).

– **L'état de santé** des époux n'est **normalement pas une condition à prendre en considération** pour autoriser ou interdire le mariage. Mais comme pour la vieillesse, si l'état de santé conduit à une **altération de la santé mentale de l'individu**, cela pourrait avoir une **altération du consentement de la personne**.

– **Sociologiques** → empêchement à mariage qui **reposent sur des interdits sociaux**. Deux interdits sociaux fondamentaux : le rejet de la polygamie, l'interdiction de l'inceste.

– **Rejet de la polygamie** = condition de monogamie. On **ne peut être marié à une seule personne**. **Art 147 du CC**, on ne peut contracter un second mariage avant dissolution du premier. Pour pouvoir se marier il faut donc **fournir un extrait d'acte civil d'au moins 3 mois**. Malgré ce contrôle, des cas existent encore, notamment dans le cas de personne de nationalité étrangère. Si un mariage a lieu alors qu'un des deux était déjà marié on **peut annuler le mariage**. **Art 433-20 du CP** qui fixe des sanctions pour la polygamie.

– Interdiction des mariages incestueux (hexogamie), les futurs époux ne doivent pas appartenir au même groupe familial. D'abord, pour des raisons biologiques pour éviter les méfaits liés à la consanguinité, mais également pour protéger une certaine conception des structures familiales, entraîne une confusion des places au sein d'une famille. **Art 161 du CC**, interdit les mariages entre membres de même famille, même alliance et adoption. En **ligne directe**, le **mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants, et alliés dans une même ligne**. Pas de mariage entre père/fille, grand père/fille, etc. Idem entre un homme et la fille de son épouse. → seulement en ligne directe. Depuis loi de 1975 pas d'empêchement entre les autres lignes.

Mais exception en ligne directe : dispense possible mariage entre alliés, doit être **autorisé par le Président de la République et pour cause grave, et encore faut-il que la personne qui a créé l'alliance soit décédée**. (possible épouser le fils de l'ex époux si celui ci est mort).

Ligne collatérale art 162 : le **mariage est prohibé entre frère et soeur** (et demi), et le mariage est aussi prohibé entre oncle/niece, neveu /ante, etc. Toutefois, art 164, **dispense délivrée par Président de la République, pour cause grave**. => pas interdiction pour les cousins

* **4 décembre 2013 arrêt première chambre civile n°12-26.066** → les empêchements à mariage sont censé prohiber tout mariage dit incestueux lorsqu'ils sont concernés par art 161 et suiv. Dans l'arrêt, les personnes entrent dans les catégories des interdictions à mariage, mais sont tout de même mariés. Une des deux décède, et donc succession. Les héritiers, qui ne toucheraient pas l'héritage car le conjoint à plus de droit, ont choisis de dénoncer le mariage frauduleux. Ils demandent l'annulation du mariage. Normalement, d'après le CC, le mariage ainsi prononcé l'a été en contradiction avec les articles du CC, et devrait donc être annulé. Cependant la solution de la cour de cass est différente. Outre le droit interne, les juges doivent prendre en compte le droit fondamental, tel que le droit à la vie privée et familiale. Les deux époux vivaient mariés depuis près de 22 ans, avaient des enfants communs etc, personne n'a remis en cause le mariage. → mise en balance des intérêts entre la liberté et la vie privée, et le droit du mariage. La Cour de cass tranche : durée du mariage, vie privée, etc, le fils cherche juste à s'enrichir, = prononcer la nullité du mariage porterait atteinte de façon disproportionnée à la vie privée et des familles de l'art 8 de la CEDH. On a écarté une loi au bénéfice d'un droit fondamental.

CM3 : 30/01/2025 (absente, cour Isaure)

– **Psychologiques** → Il faut que les époux consentent au mariage de manière libre et consciente. Mais avant d'être donnée de manière libre et consciente, il faut que ce consentement **exprime une intention matrimoniale**, c'est à dire la volonté des époux de se marier et de former un couple unis par les liens du mariage, ainsi que se soumettre aux effets du mariage. Dès lors qu'elle fait défaut, le consentement n'existe pas.

– L'existence du consentement : c'est une condition exprimée clairement à **l'article 146 du Code Civil**, qui exprime la chose suivante : « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de **consentement**. ». C'est donc une condition nécessaire à la validité du mariage. Son expression va répondre à certaines règles qui vont permettre de vérifier si le consentement est bien réel ou pas, et de vérifier si les époux consentent bien à tous les effets du mariage qui en découleront.

L'expression du consentement se fait lors de la célébration du mariage où ils vont s'exprimer publiquement sur leur souci de former un mariage avec leur époux (**art 75**) => l'officier d'Etat civil, va tour à tour, demander au futurs époux s'ils souhaitent se prendre mutuellement pour époux, ce à quoi ils devront acquiescer pour que le mariage soit conclu.

Dans le cas des mariages in extremis, certaines décisions de justice sont venues admettre (**arrêt C de cass 2006**) qu'un simple rôle du futur époux suffisait à caractériser son consentement. Il faut également que ce consentement soit bel et bien réel, et pour ce, il faut que l'état mental et psychologique du futur époux soit suffisamment sain pour exprimer un consentement valide.

Ex : personne en capacité physique mais qui a un trouble psychologique = altération des capacités mentales.

Arrêt 1ere chambre civ 20 avril 2017 => un mariage devait être annulé en raison de l'altération des facultés mentales d'un individu placé sous curatelle. Cette personne avait rencontré une personne et s'était marié trois mois après. Dans cette citation, les juges ont annulé le mariage pour défaut de consentement réel.

Il faut aussi que ce consentement porte sur l'intégralité des effets du mariage = existence d'une intention matrimoniale. On s'intéresse au but poursuivie par les futurs époux. En se mariant, les époux entendent assurer toutes les conséquences de l'union matrimonial, c'est à dire les effets personnels et les effets pécuniaires du mariage. Donc lorsqu'ils se marient, les époux entendent se soumettre à l'ensemble de ses effets. Ils vont se soumettre à l'intégralité du régime matrimonial. Leur objectif n'est pas seulement de bénéficier de tel ou tel avantage du statut matrimonial. Si on se marie avec une personne, peut-être cela va apporter des avantages financier (moins d'impôts) mais ça ne doit pas être la seule raison.

Il peut exister des situations où des individus décident de se marier dans le seul but de bénéficier d'avantages particuliers (ex : acquisition de la nationalité). On parle de mariage blanc, c'est à dire des mariages fictifs ou simulés. => un mariage qui n'est pas dicté par une intention matrimoniale mais par des intentions accessoires. Ce type de mariage n'est pas valable juridiquement et encourt la nullité, et la nullité peut être demandée par tout intéressé pendant 30 ans à partir de la célébration de celui ci.

Arrêt appietto C cass 1963 : Un couple s'est marié pour seule intention du mari de légitimer un enfant dont il était le père, puis de divorcer. La cour de cass a dt que l'annulation du mariage devait être prononcée.

Ces mariages blanc sont sous le feu des projecteurs et ont donné lieu à une réforme du 24 aout 2021 dans le cadre d'une loi séparatiste qui est venue renforcer le contrôle de ces mariages blancs, en modifiant les articles 63 et 175-2 du CC, en prévoyant que désormais, en cas de suspicion de fraude, l'officier d'EC va être tenu d'organiser un entretien individuel afin de s'assurer que les deux époux poursuivent bien une intention matrimoniale. Dans tous les cas, l'officier d'Etat civil, s'il n'est pas convaincu, doit saisir le Procureur de la République, à condition qu'il n'existe un doute sérieux quant à l'intégrité du consentement. Il pourra décider ou non de la tenue du mariage.

– Un consentement libre et éclairé : Renvoie au fait que le consentement doit présenter certaines qualités, il ne doit pas être vicié (même chose que pour le droit des contrats).

– **Violences** commise à l'égard de l'un des futurs époux (180 CC)

Une contrainte s'est exercée sur l'un des futurs époux pour le forcer à consentir au mariage. Elle peut être physique ou psychologique. On va même jusqu'à parler de crainte révérenciel à un ascendant.

– **Erreur** commise par l'un des deux époux (180 CC)

Il peut y avoir erreur sur la personne ou sur les qualités essentiels de la personne.

° L'erreur sur la personne c'est une hypothèse assez restreinte qui renvoie à un cas particulier = erreur sur l'identité du conjoint qui se faisait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas vraiment (cas rares et bien identifiés car l'erreur est facilement caractérisée).

° Les erreurs sur les qualités essentielles de la personne est plus difficile à cerner car il n'existe pas de liste des qualités essentielles d'une personne => dépend des gens. Ici, les qualités essentielles doivent être comprises comme les qualités qui, d'un point de vue individuel et sociologique, sont regardé comme étant liés à la conception du mariage. Celui qui se prêtant victime d'une erreur sur les qualités essentiels de son conjoint doit non seulement démontrer que la qualité en cause était essentielle pour lui d'un point de vue subjectif, mais aussi qu'il apporte la démonstration que cette qualité était objectivement essentielle, cad essentielle pour l'opinion commune. Pour prouver qu'elle l'est, les juges vont en réalité vérifier si cette qualité avait une incidence sur la vie matrimoniale du couple.

Jurisprudence => erreur commise sur le transsexualisme de l'un des époux, erreur sur la séropositivité de l'un des époux (mais évolution donc la jurisprudence peut évoluer), erreur sur le passé pénal de l'individu, erreur sur le trouble psychique

CA Montpellier 2019 : une épouse avait été trompé sur un certain nombre de qualités de son époux. Il avait menti sur son identité, son travail, sa situation pénale, sur sa situation maritale.

Arrêt de la cour d'appel de Douai 2008, qui posait la question de savoir si la virginité pouvait être une qualité essentielle. La cour a dit que selon le caractère subjectif et objectif en considérant que peut être la virginité pouvait être subjectivement une qualité essentielle mais que ça ne pouvait pas l'être objectivement. => pas retenue par les magistrats.

=> il est possible de demander la nullité du mariage

– **Conditions de forme** -> Le mariage n'est pas qu'un contrat entre personnes privée, c'est une institution sociale qui organise les rapports entre les individus au sein de la société, et a donc une dimension publique. Il y a donc un certain nombre de formalités mises en place, et ses formalités prennent notamment la forme de l'intervention d'un officier d'État civil au moment de la célébration nuptiale qui sera chargé de la rendre publique, mais avant même la célébration, un certain nombre de formalités devront être accomplies dans le but de permettre aux autorités publiques de s'assurer de la régularité de la situation par rapport aux différentes règles.

– Formalités préalables à la célébration : il y a deux objectifs :

° Vérifier l'existence d'une intention matrimoniale, l'officier d'Etat civil le fait par l'audition des deux époux. Elle est le fait de l'officier d'EC qui va prendre connaissance d'un certain nombre de pièces préalablement déposées par les époux. (copie récente d'un acte de naissance pour vérifier l'identité des époux et qu'il n'y a pas un autre mariage non dissout, éviter la présence d'inceste art 161 et suiv CC, vérifier l'âge nubile). Puis il va rencontrer les époux pour s'assurer de leur intention matrimoniale. 14 Novembre 2006 : lutter contre les mariages forcés et les violences. Mais cette audition n'est pas obligatoire, ne pas être requise par l'officier d'État civil, ou si il y a un cas d'impossibilité quelconque qui empêche l'audition, donc dans la plupart des cas, l'audition n'a pas lieu. Elle peut être commune ou individuelle.

° L'information des tiers pour qu'ils puissent formuler des oppositions éventuelles au mariage (art 63 CC) = la publication des bans. La future célébration du mariage doit faire l'objet d'une publicité, être connue de tous. L'officier d'EC doit afficher à la mairie et dans les mairies du domicile de chaque époux, le projet de mariage et cela pendant 10 jours (Art 63 et suiv et 166 CC), mais il existe des exceptions qui vont pouvoir être accordés par le procureur pour faute grave (ex : personnes célèbres). Elle empêche la célébration du mariage. C'est un empêchement prohibitif : si le

mariage est tout de même célébré, on ne pourra pas demander l'annulation.

Empêchement dirimant : même après le mariage, on puisse en demander l'annulation

– Formalités propres à la célébration elle même : Formalités importantes et encadrées par le CC (art 75) qui prévoit un certain nombre de formalités :

◦ La cérémonie doit être laïque : le mariage est une célébration mais elle ne peut être une célébration religieuse, par conséquent, la célébration religieuse doit se faire dans une temps différent et est facultative. Elle n'a aucune influence juridique quand au mariage des époux. Elles doivent avoir lieu après le mariage civil. Car en pénal, un ministre du culte, peut être puni pour avoir célébré un mariage sans qu'il ne lui est été justifié l'acte de mariage réalisé en mairie.

◦ Le lieu de la célébration est fixé à l'art 165 : le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier d'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou l'un de ses parents. A titre exceptionnel, le mariage pourra même être célébré au domicile de l'un des époux avec l'autorisation du Procureur de la République en cas d'empêchement grave.

◦ La publicité : les portes de la salle doivent être ouvertes a peine de nullité du mariage.

◦ La date : le mariage doit intervenir dans un délais de 10 jours après l'exposition des bans, et dans l'année qui suit.

◦ La présence des époux et de 2 (4 au plus) témoins qui peuvent être des parents, des amis (la lois est très libérale car elle prévoit que ça peut être des personnes de toutes les nationalités). Toute procuration est interdite.

→ Exception en cas de guerre ou opération militaire (motif grave), en l'absence de l'un des époux mais autorisation conjointe du Ministre de la Justice et de la Défense. Cette situation concerne les mariages post mortem. L'accord des ministres ne suffit pas car il faut prouver que la personne disparue ait donné de son vivant le consentement au mariage devant un officier d'état civil, soit devant un agent diplomatique. En vertu de l'article 171 du code civil, le Procureur de la République peut (pour des motifs graves) autoriser le mariage en cas de décès de l'un des futurs époux dès lors qu'on arrive a réunir suffisamment de preuve de son consentement au mariage (debut de l'organisation du mariage).

◦ Les rituels, cad le déroulé de la cérémonie. Le CC règle le déroulé de la cérémonie du mariage prévoyant que l'officier d'État civil doit lire les articles 212, 213, 214, 215, 271-1 (autorité parentale) puis l'officier d'état civil doit demander aux époux si ils ont établie devant notaire un contrat de mariage et si ils veulent se prendre pour époux (art 75). Après il peut prononcer le mariage

◦ L'acte de mariage : rédigé par l'officier d'EC, et il va devoir être signé par lui même, les époux, les témoins et au besoins par les représentants légaux si c'est un mineur

Acte de mariage prononce l'existence du mariage. Les effet du mariage débute après.

Les effets du mariage dépendent de l'existence ou non de ce contrat de mariage.

2/ Les sanctions des conditions de formation du mariage

Parmi les conditions, certaines sont plus importantes que d'autres car elle touchent la conception même de ce qu'on a du mariage => règle d'ordre public

Ex : la condition liée à la monogamie va être plus importante que la condition de la publication des bans. Par conséquent, parmi les empêchement au mariage, il va falloir distinguer ceux qui sont grave de ce qui le sont moins. C'est empêchement à mariage étant le non respect d'une condition de formation du mariage.

Il faut distinguer :

- Les empêchement prohibitifs : prohibe la célébration du mariage, obstacle qui intervient en amont.

Cet obstacle intervient par une opposition en amont et ne peut en demander la nullité

Ex : la condition de la publicité qui passe par la publication des bans

- Les empêchements dirimants : vont permettre de faire opposition a un mariage (agir en amont) mais sont particulièrement grave donc on va considérer que même si le mariage est célébré de tel empêchement vont permettre ensuite d'être invoqué afin de pouvoir demander la nullité du mariage.

Ex : la condition de monogamie, d'exogamie, de consentement libre et éclairé, les règles de formes liés a la présence d'un officier d'état civil, des futurs mariés

=> permet d'éviter la formation de mariage qui ne rempliraient pas les conditions prévue pour leur existence et permet d'éviter les situation ou on va pouvoir demander l'annulation du mariage car seul le non respect des conditions les plus grave pourront entrainer l'annulation du mariage.

° LES OPPOSITIONS AU MARIAGE :

Elle intervient en amont de la célébration, et l'officier d'ÉC doit refuser de célébrer le mariage (encourt une sanction pénale si il ne le fait pas) s'il le constate lui même ou lorsqu'une personne a formé opposition = acte juridique par lequel une personne va avertir l'officier d'état civil de l'existence d'un empêchement à la célébration du mariage. Le droit d'opposition est ouvert a certaines personnes seulement listé aux articles 172 et suivants = conjoint actuel du futur époux, les parents pour tout motifs, les ascendants ou collatéraux si il n'y a pas d'ascendant mais uniquement pour certains motifs (si le conseil de famille est requis ou les cas où la personne qui va se marier est atteinte d'un trouble mentale mais dans ce cas, nécessité d'ouverture d'une mesure de protection), les représentants d'un majeur vulnérable, le ministère public, le Procureur de la République qu'en ce qui concerne les empêchement dirimants.

Les effets : le mariage ne peut être célébré, cad que l'officier n'est pas juge du bien fondé de cette opposition. Mais les époux vont pouvoir demander en justice le retrait de l'opposition au mariage. La demande de main levé de cette opposition doit être formé par les époux devant le tribunal judiciaire qui devra statuer dans les 10 jours. Si ils ne font pas cette démarche, il devront attendre un an afin de se marier car au bout d'une année, l'opposition devient caduque (SAUF : lorsqu'elle est le fruit du ministère public)

° L'ANNULATION :

Peut être demandé en justice en présence d'un empêchement dirimant, lorsqu'une condition dirimante n'a pas été respectée. Ces demandes en nullités vont devoir respecter certaine règles, autrement dit, n'importe qui ne va pas pouvoir demander la nullité du mariage (les règles seront différentes selon si on est en nullité absolue ou relative). Lorsque la nullité est prononcé par un juge, les effets seront toujours les mêmes

– Les conditions de l'action en nullité :

Les **empêchement dirimants** sont plus graves que les **empêchements prohibitifs**. On retrouve ce critère de gravité au sein même des empêchement dirimants (conditions variées : âge, inceste, consentement...) Les conditions liées à la vérification du consentement libre et éclairé des époux permet de **protéger les intérêts de l'époux concerné, c'est un préjudice personnel**. C'est un empêchement à mariage dirimant dont le seul intérêt est la protection personnel de l'intéressée..... Là, les intérêts qui sont protégés sont tout autres car les concernés peuvent être consentants, mais ce **type d'union va aller à l'encontre des conceptions sociales du mariage**. Autrement dit, dans ce type de cas, l'intérêt ne sera plus un intérêt particulier mais un intérêt général. Certain visent à protéger des intérêt particulier (nullité relative) ou l'intérêt général (nullité absolue)

* La **nullité relative** va **permettre de sauvegarder les intérêts privées**, qui vise à protéger les intérêts particulier de l'un des époux, parmi les conditions qui y donnent lieux, on retrouve les vices (**180 CC**), le défaut d'autorisation des parents en cas d'un mariage d'un mineur (**182 CC**). Cela signifie que les personnes qui vont pouvoir demander la nullité ne seront pas les même que pour une nullité absolue :
=> **seul l'époux dont le consentement a été vicié peut demander l'annulation de son mariage**. Mais lorsque la violence prend la forme d'une violence physique, ou morale, le ministère public va pouvoir agir (protection en lien avec l'ordre public). En cas de manque d'autorisation, c'est au mineur lui même qui doit demander la nullité, ou aux personnes qui devaient donner leur consentement. Toutefois, le vice du consentement ou le défaut d'autorisation va pouvoir faire l'objet d'une confirmation, cad qu'il y a des cas où le mariage va pouvoir être confirmé = l'approbation au mariage par ceux dont le consentement a été vicié ou par ceux qui devaient donner leur autorisation au mariage. Si la victime du vice considère que ce vice ne lui porte pas préjudice, autant confirmer le mariage.

* La **nullité absolue** concerne les **empêchements les plus graves et donc la conception même du mariage dans la société, et pas l'intérêt particulier d'un époux**. Le défaut de consentement, l'absence de comparution des époux, la polygamie, l'inceste, la clan destiné du mariage, l'incompétence de l'officier d'état civil...

L'action d'annulation va être entrouverte bcp plus largement : les époux, toute personne qui a un intérêt, ministère public qui pourra dès lors qu'il en aura connaissance.

La confirmation est impossible car cela concerne des règles impératives, et une telle confirmation n'aurait aucun sens car toute personne qui a un intérêt peut agir en annulation du mariage.

CM4 : 6/02/2025

– Les effets de la nullité

Les effets seront **toujours les mêmes quelque soit la nature de la nullité** demandée. Dans tous les cas, le **mariage sera anéanti rétroactivement** (anéantissement rétroactif) -> nullité du mariage pour l'avenir mais surtout dans le passé. Un **mariage annulé n'existe plus pour l'avenir est n'est censé n'avoir jamais existé**. Alors que le **divorce, lui, n'a un effet que pour le futur**.

Pour la nullité, comme le mariage est censé n'avoir jamais existé, les **époux sont censé n'avoir jamais pu bénéficier des effets du mariage**. => entraîne des difficultés. Le mariage entraîne des effets, personnels ou patrimoniaux, et ainsi on va revenir sur l'ensemble de ces bénéfices. (Ex : un époux qui obtient la nationalité française grâce au mariage, mais s'il est annulé, la nationalité sera devenue

caduc. Le **droit prévoit une atténuation** : à travers le **mariage putatif = art 201 du CC**. « Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins des effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi, si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, alors le mariage produira des effets qu'en faveur de cet époux. »

→ Ainsi, l'époux de bonne foi peut continuer (malgré l'annulation) à utiliser le nom de l'époux, la nationalité restera acquise...

Dans tous les cas de nullité, la **putativité va jouer au bénéfice des enfants du couple**, peut importe la bonne ou mauvaise foi des parents. Question du lien de filiation par exemple.

C – Les effets du mariage

Deux types d'effets, les effets personnels et les effets patrimoniaux :

1/ Les effets personnels

« Des devoirs et des droits respectifs des époux » **art 212 à 226 du CC**.

Ils sont réciproques, **chaque époux a des droits et des devoirs envers l'autre**. Certains des articles évoquent cependant l'obligation des deux époux à respecter des droits et des obligations dans l'intérêt de la famille. On va distinguer dans un premier temps les devoirs des époux l'un envers l'autre, puis ceux imposés aux deux époux.

a) Les devoirs imposés aux deux époux pour la direction de la famille

Article 213 du CC « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et ils préparent leur avenir. » → notion récente dans le droit de la famille. Avant, les époux n'étaient pas placés sur un pied d'égalité concernant la direction de la famille. La femme devait obéissance à son mari et c'est ce dernier qui avait le pouvoir de diriger la famille. Maintenant, **les deux membres du couple prennent ensemble les décisions importantes** concernant la famille. Par exemple, **art 215**, les **deux époux choisissent ensemble le lieu de résidence de la famille** = pouvoir à deux têtes. → Que faire lorsque le couple n'est pas d'accord ? Doit-il y avoir un contrat entre les époux etc.

Pour éviter ça, le **droit présume l'entente des deux époux pour les actes usuels**. (les courses quotidiennes, etc).

b) Les devoirs réciproques entre les époux

Les **époux se doivent l'un à l'autre certains devoirs**. Devoir fondamental : le **devoir de communauté de vie** → résulte d'autres devoirs (devoir de fidélité, de secours et d'assistance).

Ces devoirs vont donc **avoir des effets juridiques**. Ces devoirs ne sont généralement pas invoqués pendant le mariage, mais plutôt lors du divorce, pour le reprocher à l'autre. Ce sont des indices pour témoigner de l'entente ou non des époux.

– **Le devoir de communauté de vie** : **obligation fondamentale**, c'est le devoir essentiel du mariage, grâce à lui, les autres devoirs vont pouvoir être accomplis. Lors de la rédaction du CC, en 1804, il prévoyait une obligation de cohabitation **art 214** « la femme est obligée de vivre avec son mari et de le suivre partout où il souhaite résider ».

Aujourd'hui les choses ont changées : loi 4 juin 1970, le CC évoque maintenant une communauté de vie qui s'impose aux deux époux.

La **communauté de vie se détache de la cohabitation**. On retrouve un aspect d'avantage moral que matériel. Il n'y a pas une obligation de cohabitation, les époux ne sont pas obligés de vivre sous le même toit. C'est plutôt une **volonté commune des époux de s'engager l'un envers l'autre**.

Art 108 du CC -> les époux ne sont pas obligés de vivre ensemble.

Il est donc complexe pour un juge de faire respecter cette communauté de vie.

Indices qui permettent au juge de savoir si le devoir de communauté de vie était respecté :

° La **communauté de toit** : pas une obligation, seulement un indice -> on considère tjr qu'en principe les époux doivent cohabiter sous le même toit, c'est la **concrétisation de l'union matrimoniale**. **Art 215 alinéa 2** : « les époux choisissent d'un commun accord de la résidence principale » = ils vivent ensemble. Mais comme ce n'est pas une obligation, en cas de désaccord sur le choix de la résidence principale, le juge ne peut pas imposer à l'un ou à l'autre d'aller vivre avec son conjoint, il ne peut que leur accorder une résidence séparée.

Arrêt 12 février 2014, Chambre civ 1ere, Cour de cass -> reprend l'un des effets du mariage, la nationalité. Épouse algérienne qui épouse un français, et un an après elle va vivre à Paris et le mari reste en Creuse. 4 ans après le mariage, l'épouse demande l'acquisition de la nationalité. Les autorités françaises refusent car les époux ne partagent pas de communauté de vie (mariage blanc). La cour de cass a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel, pour des motifs d'ordre pro les époux peuvent avoir des domiciles diff sans qu'il soit porté atteinte à la communauté de vie. La communauté de toit ne suffit pas en soit. Mais lorsque les deux époux ont choisis de cohabiter, et que l'un d'eux part ensuite pour des raisons x ou y, l'autre époux, celui qui subit le départ, pourra le lui reprocher dans un divorce.

° La **communauté de lit** (habitudes sexuelles) -> on l'appelait autrefois le **devoir conjugal** = **l'obligation qu'avait les époux d'entretenir des relations sexuelles**. La communauté de lit suppose en principe l'obligation de relations sexuelles puisque **mariage sert à fonder une famille**. Évolution de nos jours, puisque admission du mariage entre personnes de même sexe et adoption, PMA etc. Aujourd'hui, **ce n'est pas une obligation dont on peut demander l'exécution forcée**. Là encore, la communauté de lit n'est qu'un indice de la communauté de vie. Sanction de ce défaut de relation sexuelles entre époux : la jurisprudence prend en considération 2 sortes ; les relations sexuelles ne sont pas une obligation mais un devoir, dont le non respect peut entraîner la dissolution du mariage, ou l'engagement de la responsabilité de la personne fautive (dans le cadre d'un divorce) arrêt 3 mai 2011. Dans un second temps : dans certaines situations le défaut de relations sexuelles peut être considéré comme une non-exécution de l'intention matrimoniale. arrêt 19 dec 2012 défaut de communauté de lit.

Arrêt du 7 novembre 2019 cour d'appel de Versailles : arrêt qui prononce un divorce pour faute à l'encontre d'une épouse qui refusait de longue date tte relation intime. Elle avait été condamnée à verser des dommages-intérêt + accord du divorce. L'ex épouse a formé un pourvoi en cassation, 17 sept 2020, rejet du pourvoi au motif que le refus de relations sexuelles sans motif constitue une faute, cause de divorce. -> décision qui a fait l'objet de controverse en droit et dans la société civile. Des associations féministes ont incité l'épouse à porter l'affaire devant la CEDH sur le fondement de l'article 8 de la CEDH sur la vie privée. Décision 23 janv 2025 = condamne la France car une telle décision constitue une violation manifeste du droit au respect de la vie privée + consentement. => va avoir des conséquences sur la jurisprudence française.

° Présence ou non d'une **communauté intérêt** -> renvoie à une **notion d'affection entre les deux époux**. Les époux doivent partager une communauté affective qui se manifeste par une certaine coopération. On ne peut pas forcer quelqu'un à avoir de l'affection pour l'autre mais on peut constater

Des situations qui caractérisent un désintérêt à l'égard des époux. Ce désintérêt peut être une nouvelle faute.

c) Les autres obligations des époux

Art 212 CC « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. »

° **Le devoir de fidélité** : il est constitutif de l'obligation caractéristique du mariage, il ne **se retrouve que dans l'union marital**. Dans le PACS ou le concubinage il n'y a pas d'obligation de fidélité. -> **pas de définition exacte de la fidélité**. Elle évolue en fonction du temps et des mœurs, et aussi en fonction du sens des couples eux-mêmes. Cette obligation interdit l'adultère (exclusivité sexuelle). Outre cette dimension, cette obligation s'entend également de la fidélité morale et intellectuelle.

La fidélité est le **fait d'entretenir avec un tiers une relation de type amoureux, soit physique, soit moral ou intellectuel**. Il s'agit alors d'une attitude intime avec un tiers, quelque soit sa nature qui pourrait être considéré comme une injure par son conjoint.

Ex d'infidélités : fait d'entretenir une grande complicité intellectuelle avec une tierce personne peut être considéré comme une infidélité lorsque, par ailleurs, ce même époux se désintéresse de son conjoint. **CA Paris 1986** une femme avait des relations ambiguës avec un évêque (pas de relations sexuelles mais on pouvait considérer, vis à vis de l'époux, une infidélité). On peut caractériser l'adultère, l'infidélité lorsque l'époux entretient des relations écrites. -> Arrêt 30 avril 2014 épouse qui échangeait par mail des nues sur un site de rencontre.

-> Sanctions du devoir de fidélité : pendant longtemps, l'adultère était une cause péremptoire du divorce (le juge n'avait aucun pouvoir d'appréciation, sanction directe). Mais de plus, jusqu'en 1975, l'adultère était puni sur le plan pénal (prison pour la femme et amende pour l'homme). Aujourd'hui, c'est au **juge d'apprécier, au cas par cas, si un adultère est grave, répété, qui peut être une cause de divorce**.

Cour d'appel Paris 17 mai 2019 qui affirme que —

° **L'obligation de respect** : Ajouté au CC par loi 4 avril 2006 objectif : la **lutte contre les mariages forcés et les violences conjugales**. Chaque époux doit veiller à ne pas porter atteinte à l'autre époux ou à ses intérêts. (pas d'atteinte corporelles ou sexuelles). **Respecter de l'intégrité physique et morale de son conjoint, respecter sa liberté de conscience, de croyances, etc.** Cette obligation de respect va pour tous les couples Loi 2010 : possibilité ouverte à un époux, concubins etc, de saisir le JAF (juge affaire familiale) afin qu'il puisse délivrer en **urgence une ordonnance de protection**.

° **L'obligation d'assistance** : les époux **se doivent réciproquement de l'aide en cas de besoin** en raison de la vie commune qu'ils partagent. Le fait d'être moralement présent au côté de son conjoint lorsque ce dernier traverse des circonstances difficiles, douloureuses (pas une obligation, on ne peut pas le contraindre, mais peut caractériser une éventuelle faute lors d'un divorce).

2/ Les effets patrimoniaux du mariage

Tout ce qui concerne les règles relatives au régime primaire. → règles qui fixent des obligations patrimoniales qui s'imposent à tous les couples mariés quelque soit leur régime matrimonial.

Le régime primaire est donc applicable à tous les couples art 1388 du CC → interdit aux époux de déroger à de telles règles. (règles impératives).

Quelque soit le régime matrimonial concerné, le couple est soumis au régime primaire. (statut impératif des couples, art 216 et suiv : obligation des couples de porter secours, protection logement familial, participation aux charges, etc.

Art 215-3 les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits du logement de famille ni des meubles meublants dont il est garni.

a) L'autonomie de chaque époux

Art 220, 21, 22 et 23 du CC = offre un mécanisme prévu à l'art 220 CC selon lequel chaque époux à le pouvoir de passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toutes les dettes obligent l'autre solidairement. = solidarité de la dette ménagère

Dans certaines situations (ex époux qui dépense bcp), art 220 du CC prévoit aux alinéa 2 et 3 des exceptions importantes à cette solidarité. La solidarité n'a pas lieu en cas de dépenses manifestement excessives. La banque ne pourra pas s'adresser à l'autre époux.

Ce caractère manifestement excessif est déterminé au regard du train de vie du ménage (niveau de richesse), de l'utilité ou non de l'opération (achat d'une voiture de sport à la place d'une voiture d'étudiant). La solidarité n'a pas lieu non plus lorsque des achats à tempérament (achat en plusieurs fois) sont organisés. De plus, la solidarité n'a pas lieu non plus pour des emprunts de somme d'argent à moins qu'ils portent sur des sommes modestes et nécessaire pour la vie courante (ex emprunt pour acheter une voiture pour un enfant qui en a besoin).

Cette autonomie des époux et la solidarité entre eux et aussi assuré par d'autres articles, comme art 221 qui permet à chaque époux d'ouvrir un compte en banque et de le faire fonctionner seul. Art 222 prévoit que chaque époux peut réaliser seul un acte juridique relatif à un objet mobilier. Ils vont pouvoir les louer, prêter, vendre seul. Exception : deux catégories de biens meubles → les meubles du logement familial et les vêtements, instruments de travail, etc. (car peuvent être à l'un des conjoint et donc on peut pas vendre les outils de l'autre)

Si un époux vend seul l'un de ses biens = l'autre époux peut agir en nullité de la vente.

Art 223 CC : pose en principe que « chacun des époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires, et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. »

Art 225 CC : « chacun des époux administre et dispose seul de ses biens personnels. » Tous les biens dont il est le seul proprio il en a une disposition absolue.

CM5 : 13/02/2025

b) La sauvegarde des intérêts familiaux en matière patrimoniale

La protection du logement familial art 215-3 CC + Le devoir de secours art 212 CC + l'obligation faite à chaque époux de contribuer aux charges du mariage art 214 CC

Ces articles sont importants car permettent de contraindre, obliger un époux à assumer une partie des charges relatives à l'entretien du ménage + éducation des enfants.

Permet à un des époux d'obliger l'autre à payer, pour subvenir aux besoins de la vie courante, au besoin de la vie du couple, et surtout, à l'éducation des enfants. Même obligation générale : concerne les 2 époux, signifie que chacun d'eux doit contribuer financièrement à la vie du couple. (dépenses générales, qui vont au delà des seuls besoins alimentaires, la jurisprudence y inclut toutes les dépenses de la famille, y compris des dépenses d'agrément, tel que les voyages, les sorties, etc, ainsi que l'acquisition de bien immobilier, à condition que la somme demandée n'excède pas ses capacités). Si un époux refuse : l'autre peut le contraindre **art 214.2**.

Ce devoir de secours est important, et **se poursuit pendant toute la durée de la procédure de divorce**. De plus, ce devoir persiste même si les époux sont séparés de fait (vivent pas l'un avec l'autre mais toujours mariés).

Au delà des devoirs généraux il existe d'autres mécanismes de protection de l'intérêt familial : **art 217, 219 et 220.1** : lorsque l'un des deux époux qui, soit est hors d'état de manifester sa volonté, soit lorsqu'un époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille.

* **Première hypothèse**, **art 217 et 219** : situation généralement tragique (âge, maladie, accident), une personne **perd de ses facultés mentales ou physiques** et ne sera plus à même d'exprimer sa volonté. → le droit permet d'autoriser l'autre époux, en justice, à passer seul un acte pour lequel, normalement, le consentement de l'autre est attendu. (**217.1**)

Plus généralement, **l'art 219** prévoit que l'un des époux peut être habilité en justice à représenter l'autre de manière générale (pas seulement pour un acte particulier, mais pour toute une série d'actes et toute une période fixée par le juge).

* **Deuxième hypothèse** : l'un des époux manque gravement à ses devoirs. Parfois peut aller de pair avec la première hypothèse (maladie, etc). On peut donc combiner les articles 217, 219 ou 220. → il va dépenser trop d'argent, comportement addictifs, etc. Le **JAF peut prescrire des mesures d'urgences, tel que l'interdiction pour l'époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur les biens du couple**, même ceux pour lesquels il aurait pu normalement agir seul. (interdiction bancaire temporaire, etc).

Si les époux dans le cadre du mariage bénéficient d'une autonomie, il n'en demeure pas moins qu'il existe un certain nombre de règles prévues pour sauvegarder l'intérêt familial. (participation aux dépenses de la famille, ou alors règles de situation de crises).

c) Le régime matrimonial

Les différents régimes matrimoniaux → ils dépendent du statut matrimonial que l'on va adopter au moment de la signature du contrat de mariage.

* Statuts de régimes séparatistes

Situations patrimoniales dans les quels **chaque époux sera titulaire de ses propres biens**. Les biens de l'épouse seront séparés des biens du mari, et inversement.

- Le régime de la **séparation de biens** : assure **l'indépendance totale de chacun des époux sur leur biens**, chaque époux reste propriétaire de ses biens et de ceux qu'il va acquérir. (sauf pour les dépenses liées à la vie de famille, règles de la contribution au ménage).

- Régime de **séparation avec participation aux acquêts** : effets qui se rapproche d'un régime communautaire. Pendant le mariage, le régime est le même que celui de la séparation, chaque époux est propriétaire de ses biens. Mais lors de la dissolution du mariage, on **calcule l'enrichissement respectif de chacun des époux**, et permet de mettre à la charge de celui qui

égale l'enrichissement du mariage. Le contrat de mariage prévoit comment s'opère la répartition des biens.

* Régimes communautaires

Instaure entre les époux une **communauté de biens**. L'ensemble des biens des deux époux sont mis en communauté, les deux époux auront la propriété de ces biens à part égale. On crée donc une communauté de biens. Masse de biens dont certains seront propre à chacun des époux, et d'autres seront communs. Sur les biens communs, chacun des deux époux en aura la propriété et ils devront donc s'accorder l'un avec l'autre quant à la gestion de ces biens. À la dissolution du mariage, on va devoir partager cette communauté de biens entre les deux époux (calculs complexes entre les récompenses que se doivent les époux)

- Le régime de **communauté réduite aux acquêts** : les acquêts sont les biens acquis par les époux durant le mariage, mais aussi tous les biens qui constituent les revenus de l'activité des deux époux (salaires par exemple). Ces acquêts vont tomber dans la communauté (biens communs). Régime matrimonial commun => celui qui s'applique par défaut à tous les époux s'il n'y a pas de contrat de mariage.
- Régime de **communauté universelle** : concerne tous les biens des époux (tout en communauté).

D – Les effets du divorce

Le divorce est le fait de **mettre fin à un mariage parfaitement valide**. Dissolution du mariage que pour l'avenir, il n'a **pas d'effet rétroactif**. Le mariage a bel et bien existé, mais ne continue plus dans le futur. Il peut y avoir l'intervention d'un juge, ou de façon déjudiciarisée, sans juge. Soit les deux époux souhaitent divorcer d'un commun accord soit seul l'un d'eux veut divorcer. On parle aujourd'hui d'un **droit au divorce** : chacun a le droit de divorcer, de mettre fin à son mariage. De plus en plus facilité par des réformes : loi du 18 nov 2016 : divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat -> divorce sans juge. => facilité accrue pour divorcer mais ce dernier reste formaliste, on ne peut pas divorcer n'importe comment.

Pour divorcer il faut passer par la procédure de divorce **art 229 CC** :

- Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire **art 229-1 à 229-4**,
- Divorce par consentement mutuel judiciaire **art 230**
- Divorce par acceptation du principe de la rupture **art 233 à 234 CC**
- Divorce pour altération définitive du lien conjugal **art 237 à 238 CC**
- Divorce pour faute **art 242 et suiv**

Il y a donc deux types de divorces : le **divorce par consentement mutuel** (les deux époux sont totalement d'accord pour divorcer + bonne entente sur les effets de la rupture et du divorce), et le **divorce contentieux** (époux d'accord pour divorcer mais pas sur les effets, ou carrément pas d'accord sur le divorce).

1/ Divorce par consentement mutuel

Le législateur souhaite, d'une part, pacifier les relations entre les individus,

(créé une sorte de prime à la bonne entente), et objectif économique pour l'Etat (prend moins de temps). On veut promouvoir ces divorces par consentement mutuel.

a) Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes du notaire

C'est aujourd'hui le **divorce le plus commun**. Evolution majeure dans le droit de la famille : admet un cas de divorce complètement déjudiciarisé, sans passage devant le juge. S'inscrit dans un mouv de **libéralisation de droit de la famille**. Privatisation du divorce en faisant du divorce une sorte de contrat. **Art 229-1 et suiv du CC** -> Les époux qui souhaitent divorcer doivent s'entendre, par contrat, non seulement sur le principe de la rupture du mariage mais aussi sur les effets du divorce (personnels et patrimoniaux). Chaque époux devra être assisté par son propre avocat pour que les intérêt des deux époux soient protégés. Les avocats vont donc devoir contresigner l'acte de divorce. S'ils ne contresignent pas = annulation du divorce. **Arrêt 30 avril 2024 tribunal judiciaire de Versailles** : deux époux, la femme de nationalité étrangère, ils decident de divorcer en ayant recours a une plateforme de divorce en ligne (risqué car pas cher). Les avocats ont mal rédigé la convention. Qlque années après la femme se rend compte que les effets du divorces étaient à son détriment (garde des enfants, etc.). Annulation du divorce, mais l'ex époux avait établi un PACS entre-temps.

Pour que le divorce soit en règle : il faut la **présence des deux avocats, le divorce est fermé aux couples dont l'un des membres fait l'objet d'une protection** (curatelle etc) car persone vulnérable.

Les avocats vont élaborer avec les époux le **projet de convention**. Ensuite, ils s'échangent le projet, et ce projet **doit comporter un certain nombre d'informations** (**art 229-3 et suiv CC**) comme le nom, l'identité des époux, identité des avocats, mention expresse de la volonté des époux de rompre leur mariage et aussi de s'entendre sur les effets de cette rupture + indication du règlement complet du divorce (prévoir point par point les effets du divorce). Le **notaire va établir un état liquidatif qui doit être présent dans la convention de divorce**. Il faut aussi, lorsque les époux qui souhaitent divorcer ont un ou des enfants mineur, la mention que la ou les **mineurs ont été informé de leur droit à être entendu par le juge et qu'il ne souhaite pas user de cette faculté** -> si le mineur veut être entendu par le juge, on change de procédure de divorce. A comper de la réception de la convention adressée par les avocats, les époux vont bénéficier d'un **délai de réflexion** imposé par **art 229-4 du CC**, les époux ne peuvent pas signer la convention avant 15 jours. Après ce délai, les époux et les avocats vont se **retrouver pour signer la convention, en 3 exemplaires**, un pour chaque époux et un pour un notaire, qui va **déposer la convention au rang de ses minutes** (registres d'actes officiels du notaire) et doit vérifier la régularité de la convention. Une fois déposée, la convention prend force exécutoire => le divorce prend effet.

b) Le divorce par consentement mutuel judiciaire

Le divorce mutuel le plus ancien (1975). Ce qui le caractérise = **repose sur une homologation judiciaire de la convention de divorce établie par les époux**. (le juge homologue un acte privé) le juge ne va homologuer l'acte que s'il considère que la convention respecte un bon équilibre entre les époux.

Ce divorce est devenu résiduel, l'art 230 précise qu'il n'est ouvert que dans le cas où, lors d'un divorce par consentement mutuel basique, l'enfant demande à être entendu par un juge. Ce divorce repose lui aussi sur un accord complet des époux, sur la rupture et sur ses effets. Le juge ne va pas trancher quant aux effets du divorce, ce sont les époux, dans le cadre de leur convention.

Le juge va convoquer les époux à une audience, et va les entendre, séparément puis ensemble avec leurs avocats, ainsi que le mineur. Le juge va ensuite avoir 3 possibilités :

* Si toutes les conditions légales sont réunies, l'intérêt de l'enfant est préservé etc, il peut homologuer la convention et prononcer le divorce.

* S'il constate que le consentement de l'un des époux n'est pas libre ou que la convention ne préserve pas l'intérêt de l'époux ou de l'enfant, il va refuser de prononcer le divorce, puis ouverture d'un délai de 6 mois pour que ces derniers puissent élaborer une nouvelle convention. (si a nouveau caduc, la procédure est annulée.)

* Si le juge considère que la convention ne protège pas assez soit époux soit enfant, mais considère qu'on pourrait modifier assez simplement la convention : le juge peut modifier la convention avec accord des deux époux et ensuite homologuer la convention et prononcer le divorce.

CM6 : 27/02/2025

2/ Les divorces contentieux

Lors de ces divorces, les époux vont être en désaccord, soit sur le principe même du divorce, soit sur ses effets etc.

Le juge va être amené à trancher un litige qui existe entre les époux et qui les oppose, pour ce faire le litige va pouvoir être tranché en suivant 3 procédures différentes, autant de procédures distinctes pour divorcer.

Les divorces vont pouvoir être distingués selon les motifs qui sont à l'origine du divorce. Malgré ces 3 régimes de divorces distincts, il existe une procédure du divorce contentieux, qui malgré tout, est identique pour chacun d'eux.

a) La présentation des divorces contentieux

Ils sont au nombre de 3 :

- le divorce pour acceptation du principe de la rupture
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- le divorce pour faute

– Le divorce pour acceptation du principe de la rupture :

Prévu à l'article 233 du CC : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. »

Ce divorce est utile lorsque les époux sont d'accord sur le principe de la rupture mais ils ne parviennent pas à s'entendre sur les effets du divorce. (garde des enfants, répartition des biens etc).

Ce divorce est un **divorce pour causes objectives** -> pour prononcer ce divorce on ne va pas s'intéresser aux torts, fautes des époux. La cause du divorce ne réside pas dans la faute qu'aurait commis un époux sur l'autre mais dans le fait qu'ils s'accordent pour divorcer. La demande en divorce peut être **faite par les 2 époux ensemble**, par le biais d'une **requête conjointe**, qui suit un accord sur le principe de la rupture déjà acté et signé par les époux devant les avocats, qui vont contresigner. Cet acte **comprend uniquement l'accord sur la rupture du mariage et ne précise pas les effets de la rupture**. La requête peut être déposée devant la juge sans qu'il n'y ait nécessairement l'acte.

Ce type de divorce peut aussi émaner **d'un seul époux**, sans que l'autre ne le fasse -> il y a absence de requête conjointe, mais la procédure peut quand même débiter car **l'autre époux peut accepter le principe de la rupture à tout moment de la procédure**. Si le juge a la conviction que les **2 époux sont d'accord pour divorcer**, il va **prononcer le divorce** et va statuer lui-même sur les effets du divorce, soit sur l'ensemble des effets, soit seulement relativement aux effets litigieux. **Art 234 CC**.

L'époux placé sous un régime de protection (tutelle ou curatelle) peut désormais agir sur le fondement d'un tel divorce. Avant cette loi, les époux sous régime de protection ne pouvaient pas demander le divorce sur ce fondement.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Divorce ancien, prévu et créé par la loi du 11 juillet 1975. A l'origine conçu différemment : divorce pour rupture de la vie commune. Loi du 26 mai 2004 qui a renommé et assoupli les conditions de mises en oeuvre pour qu'il soit davantage prononcé.

Les conditions pour utiliser ce divorce :

Article 237 du CC : « Le divorce peut être demandé par un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

L'article 238 explique que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la **cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparé depuis 1 ans** lors de la demande en divorce.

-> le fait que les époux ne vivent plus ensemble ne suffit pas : il **faut apporter la volonté des époux de rompre la cohabitation**. L'intention d'un seul des deux suffit.

= **Élément matériel** (vivent plus ensemble) et **élément intentionnel** (ne veulent plus vivre ensemble)

Le droit impose la séparation d'une année au jour de la demande en divorce.

Cas particulier **Art 238-2** : les époux ne sont pas obligés, dès la demande de divorce au tribunal, **d'indiquer les motifs de la demande** (divorce pour faute ou divorce pour altération etc). Dans ces cas là, on ne peut pas appliquer le délai de séparation, il sera calculé à partir du moment du prononcé du divorce.

Cette **séparation doit être continue** : si les époux ont de nouveau cohabité ensemble entre-temps et se sont re-séparés, le délai repart à 0.

C'est à l'époux qui demande ce divorce de prouver que le délais de séparation légale s'est bien écoulée (témoignage, facture d'abonnement téléphone, etc).

° Technique de la demande reconventionnelle Art 64 CPC: peut être demandé à la suite de la demande de divorce pour faute déposé par l'autre époux. Dans ce cas là, si le juge est amené à étudier la demande reconventionnelle, il peut prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans avoir à respecter le délais de séparation d'un an.

→ Cette demande reconventionnelle peut être formée par le défendeur, et permet à celui-ci de présenter ses moyens de défense et d'attaquer le demandeur en soumettant une nouvelle demande.

→ le juge va d'abord statuer sur la demande de divorce pour faute et s'il constate qu'un des époux ou les deux ont commis des fautes il va prononcer le divorce pour faute. Mais si le juge considère que les conditions pour divorce pour faute ne sont pas remplies, le juge va statuer sur la demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

– Le divorce pour faute :

C'est le divorce contentieux par excellence : il va s'agir d'évoquer les griefs des époux pour se libérer du mariage. Article 242 du Code Civil

° Les fautes causes du divorce : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Parmi ces conditions :

- La violation des devoirs et obligations du mariage → catégorie large qui englobe les devoirs conjugaux (prévus par le code) et les devoirs innommés (jurisprudence, ce sont les devoirs qui portent sur l'honneur, comme l'alcoolisme, la jalousie excessive, comportement désagréable à l'égard des beaux-parents, etc).

- Il faut que ces violations soient graves ou renouvelées

- Il faut que la violation de ces devoirs soit imputable à l'autre époux = Le conjoint défendeur a eu la conscience et la volonté de commettre les faits qui lui sont reprochés. On ne peut pas reprocher un adultère à un époux qui a subi un viol.

- Il faut que cette violation rende le maintien de la vie commune intolérable. Renvoie à l'impossibilité suggestive de l'époux victime de ces faits de continuer à vivre avec le conjoint qui s'en est rendu coupable.

⇒ La cour de cassation n'opère pas de contrôle strict sur cette interprétation. C'est aux juges de premières instances de statuer.

° L'époux contre qui une demande en divorce pour faute est introduite en justice peut agir de plusieurs façons :

- Elaborer une défense du fond → art 245-1 CC, l'époux défendeur **va démontrer qu'il n'a pas commis de fautes**, ou que les fautes reprochées ne remplissent pas les conditions de l'article 242 du CC. Le défendeur peut aussi invoquer le fait que **sa propre faute doit être excusée en raison de l'existence d'une faute antérieure** (d'égale gravité etc) commise par son conjoint (procédé de l'excuse). Le juge dispose d'un très large champ d'interprétation, il peut soit refuser de prononcer le divorce, soit prononcer un divorce aux torts partagés.

- Défense reconventionnelle -> Art 245-2 et alinéa 3, L'époux défendeur peut répliquer à la demande principale en **déposant lui même une demande reconventionnelle** de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le conjoint peut également agir en justice pour **demande le divorce pour faute a son bénéfice**, au détriment de l'autre. Le juge peut soit rejeter la demande reconventionnelle + la demande initiale, soit rejeter l'une des demande et accueillir l'autre et le divorce sera prononcé au tords exclusif de l'un des époux, ou alors il peut accueillir les 2 demandes en divorce pour faute, et le divorce sera prononcé au tords partagés des époux.
- Invoquer une réconciliation -> Art 244 du CC, Indication d'une **réconciliation entre époux**. Une nouvelle demande peut être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation. Ici, l'un des époux peut soulever l'existence d'une réconciliation survenue depuis la demande en divorce (il cohabite de nouveau, l'un a pardonné à l'autre, etc). Cet événement constitue une « fin de non recevoir » = permet aux juges, avant tout examen de l'affaire au fond, de rejeter la demande en divorce comme étant irrecevable.

=> On remarque qu'une **procédure de demande en divorce peut aboutir de 5 façons** différentes selon la décision du juge :

- Prononce le divorce au tord de l'époux défendeur
- Rejette purement et simplement la demande de divorce
- Prononce un divorce aux tords partagés des époux
- Prononce le divorce au tord exclusif du demandeur si aboutissement de la demande reconventionnelle de l'époux défendeur
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal si l'un des époux a fait une demande reconventionnelle en ce sens et que la demande de divorce pour faute a été rejetée.

b) Procédure commune aux divorces contentieux

– Introduction et déroulé de la procédure :

Art 251 et suiv du CC : l'instance en divorce commence par une **demande adressée par les deux époux au juge**, mais cette demande peut aussi prendre la forme d'une **assignation**. Elle se distingue d'une requête conjointe, c'est un acte qui **fait débiter le procès de façon unilatérale, par lequel un demandeur en justice va citer son adverse à comparaître devant le juge**.

Le ou les époux demandeur peuvent indiquer, dès la demande, les motifs de la demande de divorce (pour faute, pour altération etc) mais le fondement de la demande n'a pas à être expliqué dès le départ.

Art 254 du CC : prévoit que dès le début de la procédure le **juge va tenir une audience aux fin de mesures provisoires** = va réunir les époux qui souhaitent divorcer et va statuer sur des mesures à prendre durant le déroulé de la procédure (concernant les enfants par exemple)

Art 255 du CC va prévoir les mesures provisoires qui peuvent être prises.

Art 256 du CC : si on est en présence de mineur, le juge va être obligé de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale.

– Passerelles, les moyens de preuve et issue de la procédure

° Les passerelles : le législateur ne perd pas espoir que les choses s'améliorent pendant la procédure. Art 247 et 247-1 du CC, le législateur prévoit des règles qui permettent de faire évoluer la procédure pour qu'elle puisse devenir une procédure moins litigieuse, voire même un divorce par consentement mutuel. L'article 247 permet de passer d'un divorce contentieux à un divorce par consentement mutuel, et l'art 247-1 permet de passer à un divorce moins contentieux que celui de départ.

° Les moyens de preuve : le demandeur doit prouver les fautes du conjoint. Mais comment ? Art 259 à 259-2 du CC qui prévoient quelles sont les preuves que l'on peut apporter au juge. Le principe est celui de la liberté de la preuve, art 259, les faits qui sont invoqués peuvent être prouvés par tout moyen, y compris l'aveu. La limite principale reste que « toutes les preuves présentées au juge doivent avoir été obtenues loyalement, sans fraude ni violence. ». De plus, les témoignages de tiers sont admis, mais les descendants ne peuvent jamais être entendus en justice relativement aux reproches qui sont invoqués par les époux l'un contre l'autre. On peut également se servir de constats réalisés par des commissaires de justice (constat d'adultère, d'abandon de famille etc), et doivent être réalisés sur autorisation judiciaire car porte atteinte à la liberté de l'époux. Mais l'utilisation de ces constats est limitée, les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés du débat s'il y a eu violation du domicile et de la vie privée.

CM7 : 6/03/2025

À l'issue de la procédure de divorce, le JAF rend un jugement et va soit prononcer le divorce, soit refuser de le prononcer, s'il considère que les faits allégués ne sont pas suffisamment établis (fautes non commises, pas de séparation pendant 1 an etc) s'il refuse de prononcer le divorce = le mariage est toujours d'actualité. Mais le juge peut organiser judiciairement la séparation de deux époux = séparation de faits, pas de droits. Le juge pourra statuer quant à la contribution des époux aux charges familiales, sur la résidence familiale, sur la garde des enfants etc. Si le juge prononce le divorce, le mariage prend fin, l'état civil des époux sera modifié (acte de naissance + acte de mariage). C'est à partir de la date de modification de l'état civil que le divorce va prendre effets.

3/ Les effets du divorce

Le divorce provoque une dissolution du mariage, n'a un effet que pour l'avenir. Les époux redeviennent chacun célibataires. Il y a aussi une disparition des liens personnels qui unissent les époux.

Parfois, suite à la dissolution du mariage = écart de niveau de vie entre les époux. Par exemple si l'un a arrêté de travailler pour garder les enfants.

Autre problématique : l'usage du nom de famille du conjoint.

a) Les effets personnels du divorce

Le divorce met fin aux devoirs conjugaux, à l'ensemble des obligations matrimoniales. (devoirs de fidélité, d'assistance, etc). Chacun des ex époux est désormais libre de contracter un

mariage avec une autre personne. Ils peuvent également se remarier ensemble (mais il faut une nouvelle cérémonie de mariage 266 CC).

Bien que les ex-époux soient de nouveau célibataires et que les droits et devoirs du mariage cessent, **ce lien matrimonial qu'ils ont partagé va laisser un certain nombre de traces, qui vont continuer à avoir des effets après divorce.**

– **Le cas du nom d'usage** : Les conjoints **peuvent utiliser le nom de l'autre durant le mariage**. Le principe **d'indisponibilité** du nom fait que, au divorce, cette exception cesse et **chacun des époux garde seulement son nom art 264 CC**, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. **Mais exception** : un ex conjoint **peut préserver l'usage du nom de l'autre dans 2 cas** : soit parce que **l'autre lui permet**, soit, le juge, lorsqu'il prononce le divorce, peut autoriser un époux à continuer à faire usage du nom de l'autre à **condition de justifier d'un intérêt légitime** (ex : il utilise ce nom dans son cadre professionnel et changer peut lui porter préjudice, ou alors pour garder le même nom que ses enfants).

– **Question des empêchements à mariage** : situations dans lesquelles une condition de validité du mariage sera défailante, ce qui peut **interdire le prononcé même de ce mariage**. Si le mariage est quand même prononcé cela pourrait conduire à une annulation. Les liens d'alliance qui unissent un époux à la famille de son conjoint disparaissent après le divorce. Mais cependant **tous les empêchements à mariage pour cause de parenté sont toujours valables**. Exemple, des ex-alliés en ligne directe ne peuvent toujours pas se marier, sans dispense possible. Mais **art 164 du CC** qui prévoit une dispense dans un cas particulier : permet au Président de la République d'autoriser mariage entre alliés en cas de cause grave et **si la personne qui crée l'alliance est décédée**. En revanche, si la dissolution du mariage n'est pas causée par la mort du conjoint mais par le divorce de celui-ci il ne pourrait y avoir aucune dispense possible.

b) Les effets patrimoniaux du divorce

– **La liquidation du régime matrimonial** : le régime matrimonial est choisi lors du contrat de mariage (ou attribué à défaut). Et ce, **afin de faciliter la liquidation**. C'est au moment du divorce, on va répartir les biens entre les époux. Dans un divorce par consentement mutuel, les **époux s'accordent à l'amiable sur cette liquidation** (droits de chacun sur différents biens). Soit les époux ne s'entendent pas, dans le cadre d'un divorce contentieux, et ce sera au **juge de fixer cet état liquidatif avec l'aide d'un notaire**. C'est en fonction de cet état liquidatif que le juge prononcera le divorce. Il est aussi possible que les époux, dans un divorce contentieux, soit d'accord sur la liquidation, dans ce cas le juge n'interviendra pas.

Toutefois **ce partage peut se révéler inégalitaire**, il peut ne pas permettre de combler les différences de niveau de vie que risque de créer le divorce entre les époux. Notamment lorsque un époux a une meilleure situation professionnelle que l'autre. Pose des questions d'équité.

– **Prestation compensatoire** : créé par la loi du 11 juillet 1975, défini à **l'art 270 du CC**. Dispose alinéa 2 « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation à l'autre ... ». ≠ la pension alimentaire qui est une aide alimentaire versée par l'un des conjoints à l'égard de l'autre (ou enfants), cad à l'égard des personnes pour lequel le conjoint est débiteur d'une obligation de secours. La prestation compensatoire, au contraire, est à destination d'un époux,

pas dans le but de subvenir à ses besoins essentiels, mais qui vise à **compenser la disparité du niveau de vie** qui va être provoquée par la dissolution du mariage.

° **Conditions d'attribution** : elle a une **nature indemnitaire** (indemniser la baisse du niveau de vie après divorce). Va **attribuer un capital à l'époux qui subit la chute du niveau de vie**. Dans toutes les situations où une épouse a sacrifié sa carrière professionnelle pour l'éducation des enfants. Il faut donc arriver à démontrer que la rupture du divorce a créé une disparité entre les conditions de vie des époux. **Les juges ont une faculté souveraine d'appréciation en la matière**, ils vont donc vérifier un certain nombre d'éléments, notamment patrimoniaux pour déterminer si oui ou non il y a une baisse du niveau de vie. Etant précisé que les **fautes éventuelles qu'auraient commises l'un ou l'autre des époux pendant le mariage ne seront pas prises en compte**. Mais **jurisprudence** : dans certaines situations, pour des questions d'équité, **les juges refusent d'accorder la prestation compensatoire, art 270 alinéa 3**, en particulier dans les situations où le divorce est prononcé aux torts exclusifs sont dans le sens de l'époux qui fait la demande de prestation compensatoire.

° **Détermination du montant** : si divorce par consentement mutuel et **les époux se mettent d'accord sur cette prestation compensatoire et se mettent d'accord sur le montant**, cela se fait sans juge, à l'amiable. Si les époux ne **s'entendent pas**, se sera aux juges de **déterminer s'il faut fixer une prestation compensatoire, et quel sera son montant**. Il va regarder quels seraient les besoins de cet époux, etc ainsi que la situation patrimoniale du débiteur au moment du divorce, tout en prenant en compte l'évolution de cette situation. Ces éléments sont fixés à **l'article 271 du CC** (ne sont pas cumulatif, juste un guide pour le juge), invite à prendre en compte la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, temps consacré à l'éducation des enfants, critères professionnels, choix professionnels fait pour faciliter celle de l'autre, critères patrimoniaux, etc. Parfois les juges prennent aussi en compte le fait que le conjoint qui doit recevoir la prestation compensatoire vit avec un nouveau conjoint.
Arrêt 4 juillet 2018 n°17-20.281.

° **La forme** : Le code civil prévoit en réalité que **la prestation peut prendre 2 formes** :

- Le **versement d'un capital en une seule fois**,
- Le **versement d'une rente en plusieurs fois** → Mais cette rente maintient les

liens entre les ex-époux après le divorce... Pour limiter ce contentieux d'après divorce, la prestation compensatoire doit être exécutée en capital. (La rente est exceptionnelle.)

Deux formes possibles de capital : versement de somme d'argent en une seule fois, ou si difficultés, en plusieurs mais max 8 ans.

Si le versement de cette somme d'argent est pas possible car grandes difficultés :

- **attribution en propriété** (transfert de biens immobilier)
- **droit temporaire d'usage**, soit en **viager** soit en **usufruit** sur un **bien immeuble**

appartenant à l'époux débiteur. (ex : droit de l'époux créancier d'habiter dans l'immeuble qui appartient à l'époux débiteur). A titre exceptionnel, par décision spécialement motivée (âge ou santé), le juge peut fixer une rente viagère **art 276**

– Le sort du logement familial : pendant la durée du mariage, **le logement familial est protégé**. Il existe une **règle de co-gestion**, chaque époux gère pareillement le logement de famille (même celui qui n'est pas proprio du logement). Permet d'éviter qu'un des époux puisse vendre seul le logement etc. Cependant, **lorsque le divorce est prononcé, cette protection tombe**. Mais malgré le divorce, le législateur prévoit **certains mécanismes qui le protège**.

° Situation où les époux sont locataires du logement : pendant le mariage, le **bail appartient aux deux époux**, même si conclu par un seul des époux avant le mariage **Art 751**, co-titularité du bail. Au moment du divorce cette co-titularité cesse, il **faut l'attribuer à un seul des époux**. Soit les époux se **mettent d'accord sur qui est titulaire**, soit ils sont pas d'accord et le **juge va décider**. Pour cela, il va prendre en compte des intérêts sociaux et familiaux des époux, et en premier, lieux, l'intérêt des enfants. Lorsque le JAF fixe la résidence des enfants avec un enfants, le parents va pouvoir bénéficier de ce bail. (éviter déménagement, changement école etc).

° L'un ou les 2 sont proprio du logement :

- Première hypothèse, un seul des époux est proprio du logement de famille : le **juge peut concéder un bail à l'autre conjoint sur cet immeuble**, si certaines conditions sont réunies, en particulier si une telle solution est conforme à l'intérêt des enfants. Cas de location forcée, qui cessera au plus tard à la majorité des enfants.
- Deuxième hypothèse, les 2 sont proprio : soit les deux époux **décident de vendre le bien et se répartissent la somme**, soit ils souhaitent garder le bien, le **juge va pouvoir décider qui sera le proprio par le biais de l'attribution préférentielle**. L'époux qui récupérera le bien **devra indemniser l'autre au montant de sa part** dans le bien qui lui échappe (= **une soulte**).

– L'attribution de dommages et intérêts : Dans le cadre d'un divorce contentieux ++, les époux peuvent **se réclamer des dommages et intérêts sur la base de deux fondements** distincts. Deux textes de lois qui permettent de réclamer les dommages et intérêts :

° Art 1240 du CC, pose le fondement du **principe de responsabilité civile** : peut demander **réparation de tout préjudice causé par sa faute au moment du divorce ou pendant le mariage**.

° Art 266 du CC : qui s'applique que dans le cas **d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou d'un divorce pour faute**. Prévoit qu'un époux peut obtenir réparation des **conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage**. Dans ce cas là, disposition qui permet d'obtenir réparation du préjudice spécifiquement causé par la rupture du lien conjugal. Cet article à un champ d'application bcp plus restreint que le 1240, qui vise tout types de préjudices.

- Parfois possible de concilier les 2
- Parfois les juges se trompent :

Arrêt cour de cass 1ere Civ 20 sept 2023 : divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. La cour d'appel condamne l'épouse à payer à son ex une somme de 1500€ sur le fondement art 266 en réparation du préjudice constitué par le fait, pour l'époux, d'avoir été privé de ses filles pendant 11 mois, en dépit d'une ordonnance de non conciliation qui fixait le domicile des filles chez le père. La cour de cass va casser l'arrêt car le préjudice indemnifié résulte de l'article 1240 et pas 266 du CC.

II – Les couples non mariés

Il existe, à côté du mariage, d'autres formes d'unions, tels que le PACS et le concubinage.

A – Le pacte civil de solidarité

Issue du mouvement de revendications homosexuels dans les années 1990. Possibilités pour des personnes de même sexe de s'unir sans remettre en cause une certaine conception du mariage. La loi du 15 nov 1999 qui intervient en donnant une définition du concubinage et en consacrant le pacte civil de solidarité en envisageant très largement, puisque dès le départ, il est ouvert aux couples de même sexes et de sexes différents.

Première version extrêmement critiquée : statut mal pensé qui créaient des blocages.

→ Réforme du 23 juin 2006, les choses ont évolué, le PACS se rapproche fortement du mariage sur certains aspects.

Défini à l'art 515-1 du CC qui dispose qu'un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par 2 personnes physiques majeures de sexes différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune.

CM8 : 13/03/2025

1/ La formation du PACS

Art 515_1 et suiv du CC : énonce un certain nombre de conditions permettant la formation du PACS.

a) Les conditions de fond

Il faut être en présence d'un couple, qui doit être composé de deux personnes physiques, qui, comme en matière de mariage, peuvent être des personnes de même sexe. Ce doit être des personnes dotées de la capacité juridique et donc, en principe, majeures. À la différence du mariage, il ne peut pas y avoir de dispense au bénéfice des mineurs. La loi précise que seul le majeur peut se pacser (même malgré émancipation).

Pour les majeurs sous régime de protection : il faut se référer aux art 461 et 462 du CC, dont les dispositions vont permettre aux majeurs protégés de se pacser, mais attention pour la signature de la convention de pacs, ils devront être assistés par leur représentants.

Il existe également des empêchements à PACS. Comme en matière de mariage, seules des personnes qui n'appartiennent pas au même groupe familial proche vont pouvoir se pacser. Le pacs n'est pas simplement un contrat d'union entre deux personnes, il a aussi une dimension institutionnelle en ce qui vise à organiser la vie de couple, telle qu'elle est admise dans notre

société. Les empêchements sont prévus aux **art 515-2 du CC**.

- A peine de nullité il **ne peut y avoir de pacs entre ascendants et descendants** en ligne directe, entre alliés en ligne directe, et entre **collatéraux** jusqu'au 3e degré inclus.
- Le pacs **ne peut avoir lieu entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans une autre forme de mariage / pacs**.

Le législateur n'a prévu **aucune dispense possible**. Les conditions pour passer un PACS sont plus strictes que celles pour se marier. Il n'y a pas de PACS posthume.

=> **Si un partenaire se marie avec quelqu'un alors qu'il est déjà pacsé, le PACS est automatiquement dissous**. (supériorité du mariage).

b) Les conditions de forme

Les partenaires doivent suivre 4 étapes pour reconnaître le pacs :

- Rédaction d'une convention de PACS
- Déclarer la convention
- Enregistrement
- Publicité

Ces étapes **formalisent un véritable contrat**, dont l'objectif va être **d'organiser les relations entre les partenaires, plus particulièrement les relations patrimoniales** entre ces derniers.

Le pacs peut être conclu de deux manières :

- **Acte sous signature privée / seing privé** -> **Rédigé directement par les parties**, sans aucune intervention.

Les parties devront donc elles mêmes faire les démarches pour déclarer la convention et la faire enregistrer. Le passage devant l'officier d'Etat civil s'appelle la déclaration. **Si les conditions sont remplies il va pouvoir enregistrer le pacs et le rendre public pour informer les tiers**.

Si certaines conditions ne sont pas remplies il peut refuser d'enregistrer la convention mais il doit motiver ce refus. (refus peut être contesté par les parties devant le tribunal judiciaire).

- **De manière authentique** -> Depuis 2006. La convention de PACS va prendre la forme d'un **acte notarié**, établi devant le notaire. Le notaire va donc **rédiger la convention en fonction des besoins et des désirs des partenaires**. C'est donc lui qui va pouvoir enregistrer directement la convention au rang des minutes. Ce sera à lui de procéder aux formalités d'enregistrement et de publicité. Mais il ne peut pas enregistrer et publier un pacs établi sous seing privé. Lorsque le notaire rédige des actes il assure leur efficacité. Si l'acte est mal rédigé, c'est le notaire qui engage sa responsabilité.

=> Réaliser une convention de pacte authentique est plus cher. Quel intérêt ? Le bénéfice de

Différence entre convention et contrat :

° **Convention** = acte juridique par lequel on exprime une volonté, et va ensuite se produire des effets juridiques.

° **Contrat** = deux parties qui veulent s'engager dans une relation contractuelle, établir entre eux des obligations, et une fois le contrat conclu il va produire des effets juridiques.

=> Pas toutes les conventions ne sont des contrats (par exemple, le testament est une convention mais pas un contrat, puisque les parties n'ont pas souhaité y figurer)

l'expertise, puisque le notaire a la parfaite connaissance des risques et danger du PACS, il va pouvoir leur expliquer les pièges à éviter, les clauses à prévoir etc.

Une fois que la convention de pacs fait l'objet d'une publication, le partenariat va produire ses effets.

2/ Les effets du PACS

Au départ, l'idée était de **faciliter, au sein du couple de partenaire, la gestion de leurs biens** (mobilier et immobilier, argent etc). Aujourd'hui, le pacs ayant fait l'objet de nombreuses reformes, il est désormais plus complet, il **existe des effets personnels** qui sont rattachés à cet union.

a) Les effets d'ordre personnels du PACS

Sur ce plan là, le PACS s'est rapproché du mariage. On retrouve un certains nombres de devoir personnels qui sont similaires, voire identiques, mais il existe quand même de différences.

*** Les devoirs qui se retrouvent dans le pacs :**

– **La communauté de vie** : **art 515–4 du CC**, l'article explique que les **partenaires s'engagent à une vie commune**. Implique donc une cohabitation entre les partenaires. Mais cette communauté de vie se définit comme dans le mariage (cohabitation au sens matériel, communauté affective)

– **L'assistance réciproque entre partenaires** : **art 515–4 du CC**, les partenaires s'engagent à une assistance réciproque (soutien moral). Cette dimension morale a été rajouté par la loi du 23 juin 2006 et est venu marquer la dimension personnelles de cette union.

*** Les devoirs que l'on ne retrouve pas dans le PACS :**

– **Existence d'un devoir de fidélité ?** → Pas à proprement parler d'obligation de fidélité prévue textuellement dans le Code Civil. Mais cette obligation de fidélité est une **obligation implicite**, que l'on pourrait déduire de la nature même de cette union. Le PACS est un contrat, c'est sa catégorie juridique. La convention de pacs va répondre, dans une certaine mesure, aux règles relatives au droit des contrat. Il **faut donc appliquer au PACS les règles et principes qui s'appliquent aux contrats**. Parmi ces principes, on retrouve le **principe de bonne fois**, prévu à l'art 1004 du CC. La bonne fois renvoie à l'idée que **les parties du contrat doivent être loyales les unes entre les autres**. Certains juristes défendent l'idée que, de ce devoir de loyauté résulte un devoir de fidélité en matière de PACS.

Arrêt cour d'appel 5 mai 2015 : un homme qui réclamait 10000€ à sa partenaire sur le fondement de l'article 1240, sur le fait que la rupture du PACS l'avait plongé dans une grande détresse, puisque cette dernière l'avait trompé. La cour rejette la demande au motif que la conclusion du pacs ne génère aucune obligation de fidélité + l'obligation de fidélité est propre au mariage selon eux.

Si l'un des partenaires est infidèle, cela peut quand même être pris en considération, de façon indirecte, dans le cas d'une rupture fautive.

- le nom de famille ? -> Aucun effet sur le nom de famille
- La filiation ? -> Pas d'effets sur la filiation. Le PACS ne va créer aucun effets sur la filiation des enfants (pas de présomption de paternité)
- La nationalité française ? Pas d'effets sur la possibilité d'acquérir la nationalité française, comme dans le mariage.

b) Droits et obligations patrimoniaux

Les partenaires s'engagent à une aide matérielle, et vont être tenus solidairement de toutes les dettes qui sont contractés pour les besoins de la vie courante. Mais règles différentes pour les régimes.

- Aide matérielle réciproque : art 515-4 du CC, les partenaires s'engagent à une aide matérielle qui prend la forme d'une obligation de contribution comme dans le mariage. Chacun des partenaires doit contribuer financièrement à toutes les dépenses du ménage (à proportion de leur facultés respectives).

- Obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante : art 515-4 du CC, « ... » -> dès lors qu'un partenaire engage de dépenses, s'endette en souscrivant par exemple a un prêt d'argent dans le but de contribuer aux dettes du ménage, l'autre partenaire est tenu solidairement. Mais il y a des conditions : il faut que les dettes soient contractées pour l'aide ménagère, la vie du couple. Cette solidarité n'a pas lieu pour des dépenses excessives (ex : voyage a Tahiti), ou pour des achats à tempérament (en plusieurs fois). Cette règle est d'ordre publique, elle est impérative. Il ne peut pas y avoir de clause dans la convention qui viendrait empêcher cette règle.

- Le régime applicable aux biens des partenaires : on va retrouver, comme pour le mariage, un certains nombres de dispositions, pour les biens de chacun des partenaires ou des deux. Les partenaire vont bénéficier d'une certaine liberté pour choisir le régime juridique qui sera censé organiser leur vie commune d'un point de vue patrimonial. Le choix n'est pas aussi étendu qu'en matière de mariage. Il existe un régime légal, qui trouve à s'appliquer a défauts de toute autre décision, dès lors qu'on est pacsé, et un régime conventionnel, qui va être décidé par les partenaires, et qui va prendre la forme particulière de l'indivision.

° Le régime légal : Régime qui se rapproche du régime de la séparation des biens du mariage. Art 515-5 du CC, si les partenaires n'évoquent pas dans leur convention le régime de leurs biens, alors s'appliquera à défaut le régime de séparation. Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il demeure possible pour les partenaires placés sous le régime de la séparation des biens de faire, en commun, l'acquisition de bien durant le PACS. Ces biens deviennent donc des biens indivisibles. Ces biens entreront dans le régime de l'indivision. Une indivision est un mode particulier d'exercice de la propriété qui n'est pas exclusif, la propriété est donc plurale. Plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien pour le tout. (calcul de la part de chacun selon combien ils ont contribué pour l'achat).

° Régime conventionnel de l'indivision : Ce mécanisme de l'indivision peut aussi être sélectionné dès le départ par les partenaires pour organiser de manière générale. Art 515-5-1 du CC, les partenaires peuvent, dans leur convention, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement de la convention. Tous les biens achetés par les partenaires au cours de la vie commune tombent dans l'indivision. Au moment de la rupture du pacs, chacun des partenaires pourra prétendre à la moitié du prix de vente.

- La protection accordé au logement familial : c'est le lieu au sein du quel le couple va fonder une famille. Ainsi, le logement de famille emporte une protection spécifique, dans le but de préserver l'intérêt des enfants. On retrouve la règle de co-titularité du bail comme pour le mariage, mais pas automatique, car pour en bénéficier les partenaires doivent faire la demande conjointe au près du bailleur, et s'ils ne la font pas, ils ne pourront pas s'en prévaloir. Néanmoins, en cas de dissolution du PACS, l'un des partenaires peut saisir le juge pour se voir attribuer le droit au bail en question.

3/ La dissolution du PACS

a) Les causes de la dissolution

La dissolution peut avoir lieu en fonction du mariage ou du décès de l'un des partenaires. En pratique, l'officier d'Etat civil qui rédige l'acte de décès ou de mariage est au courant de l'existence du PACS. Dès lors, il va en informer les services compétents pour dissoudre le PACS.

Mais, le PACS peut être dissous en raison de la volonté même des partenaires.

Si l'un des partenaires le décide, le pacs peut être remis en cause et peut aller jusqu'à la dissolution. La décision peut aussi être commune, et passera par une déclaration conjointe au près de l'officier EC. Mais elle peut aussi être unilatérale. En matière de pacs, il existe un principe de la liberté de la rupture du pacs (une volonté unilatérale suffit pour la dissolution).

Lorsque le PACS est rompu de manière unilatérale, comment doit-on procéder ? Pas de déclaration conjointe... Celui des partenaires qui décide de mettre fin au PACS doit le faire signifier à l'autre par acte d'huissier. C'est une copie de cet acte qui sera adressé à l'officier EC, qui pourra ensuite procéder à sa publication.

Mais parfois la rupture du pacs n'est pas aussi simple, puisqu'elle entraîne des conséquences litigieuses.

CM9 : 20/02/2025

b) Les conséquences de la dissolution du PaCS

La conséquence la plus importante est la modification de l'état civil des partenaires puisque ces derniers redeviennent célibataires (ou se marient).

Il n'y a aucune prestation compensatoire prévue, ni de possibilité de garder le nom de son ex-partenaire.

En principe, la liquidation des intérêts patrimoniaux est réalisé par les partenaires eux-mêmes

Art 515-7 : les partenaires procèdent eux-même à la liquidation. Mais si les partenaires sont en désaccord, c'est le juge qui va statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

-> Comme le régime légal est celui de la séparation des biens, il n'y a, en général, pas grand chose à se séparer durant la dissolution. Cas particulier pour les biens dans l'indivision (on va calculer avec le nombre de parts de chacun).

La liquidation de cette indivision peut conduire à des conflits, et si, les partenaires n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce sera au juge de décider.

De plus, en cas de rupture unilatérale du pacs, le partenaire délaissé, va pouvoir, sur le fondement de l'art 1240 CC, réclamer à l'autre des dommages et intérêts dans le but de réparer les préjudices subis lors de la rupture du pacs.

Mais attention, le seul fait de rompre le PACS n'est pas une faute en soit. Il faudra qu'il est mis fin à cette union dans des circonstances fautives, et qu'elles aient causé un dommage.

=> Le droit de rompre est absolu, mais il faut avoir l'art et la manière de rompre, il ne faut pas que la rupture soit fautive.

B – Le concubinage

Il se caractérise par sa grande souplesse par rapport aux autres formes d'union. Le concubinage est une union de fait qui se forme en dehors d'un cadre juridique, par la seule volonté des personnes de se mettre en couple. Cette absence de cadre juridique se retrouve dans sa formation, ses effets et dans sa dissolution.

Mais ce n'est pas tout à fait une zone de non droits. Il va quand même y avoir des effets non juridiques, notamment dans les droits et devoirs des concubins.

1/ La définition du concubinage

Le législateur a profité de la Loi du 15 nov 1999 sur le pacs pour consacrer un art (515-8 du CC) au concubinage. Cet article dispose que le concubinage est une union de faits caractérisé par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple.

Le concubinage étant une union de fait elle va avoir des conséquences, et c'est également une union de couple.

a) Le concubinage comme union de faits

Elle résulte de la seule volonté des concubins qui décident de vivre en couple. Les conditions de formation du concubinage échappent totalement au législateur -> le droit ne va pas intervenir en amont de l'union pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci va s'établir. Il n'y a besoin d'aucun acte solennel, aucune célébration, pas de contrat entre les concubins. La conséquence pratique de cela : en absence de règles de formalités, l'état civil des concubins n'est pas modifié.

L'intérêt de cette publicité est d'acter l'existence du mariage et du Pacs aux yeux de la société et de l'Etat.

Cette absence de formalité juridique va poser problème lorsque les concubins veulent avoir des avantages à être en couple.

On considère que les concubins peuvent prouver leur situation par tous moyens. Répond en droit au **principe de la liberté de la preuve** (attestation, aveux, témoignages, factures, adresse commune, co-titularité d'un bail, naissance d'un enfant en commun, etc). Toutefois, le législateur prévoit l'existence de deux preuves particulières constituées à titre préventif : preuve que se réservent les concubins avant même qu'il leur soit demandé de prouver leur situation de concubinage. => elles ont + de valeur que les autres preuves.

– **Déclaration sur l'honneur** dans laquelle les concubins reconnaissent leur situation : (état civil des concubins, lieu du domicile, date à laquelle ils ont commencé à partager leur vie commune) => mais sont facilement fausses. Parfois cette attestation n'est pas jugée suffisante et il faudra compléter la déclaration avec d'autres preuves.

– **Le certificat de concubinage** qui est supérieur à la déclaration sur l'honneur car délivré par la mairie du lieu de domicile du couple. Il va attester que deux personnes vivent en concubinage au même domicile. Le certificat est délivré sur le témoignage de deux personnes majeures qui ne sont pas les parents des concubins (amis, connaissances, collègues etc). Ils vont attester de l'existence d'une vie de couple durable et stable entre les deux personnes qui prétendent être concubins. Mais les communes et mairies ne sont pas obligées de délivrer ce certificat, et les mairies ne soumettent pas toutes ce document aux mêmes formalités.

b) Une union de couple

Le concubinage, art 515–8, se caractérise par une communauté de vie qui implique une vie de couple. Cette vie commune doit s'accompagner d'une communauté de lit, d'intérêt, etc. Elle renvoie donc à la communauté de vie du mariage ou du PACS(affective, morale et matérielle). La simple collocation ne suffit pas.

De plus, on s'aperçoit également que cette communauté de vie doit présenter un caractère de stabilité et de continuité -> union de fait qui perdure dans le temps, sans interruption.

Le juge, ou la jurisprudence, va apprécier souverainement et au cas par cas ce critère de continuité et de stabilité. Elle a considéré qu'on pouvait constater l'existence d'un concubinage en présence d'un couple dont l'un des membres rendait régulièrement visite à l'autre (au moins une fois par semaine), pendant 10 ans.

En revanche, dans une autre décision, des juges ont considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de concubinage après 2 semaines de relations seulement.

=> Il faut distinguer l'union libre du concubinage avec celle d'union passagère et précaire qui n'a pas vocation à durer dans le temps.

De plus, la stabilité dont il est question dans l'art 515–8, implique une exclusivité dans la relation.

2/ Les effets de droit qui naissent du concubinage

Il n'y a pas proprement parlé de régime juridique fixant les droits et obligations des concubins, ainsi que les possibles effets d'une rupture de ce concubinage. Mais, tout au long du 20e siècle et début 21e, le législateur est intervenu pour offrir un certain nombre de droits aux personnes en concubinage, créant ainsi des effets juridiques propres à cette situation de couple.

Il n'y a aucun devoir de fidélité, d'assistance, pas de lien juridique qui entrave la possibilité de se séparer etc, mais certains textes vont prévoir des droits et protections :

En matière de protection sociale, le concubin est considéré comme un ayant droit d'un assuré s'il est à sa charge effective. => ouvre des droits et des prestations sociales, en matière d'assurance maladie, la maternité, etc.

Loi du 6 juillet 1989 : règles relatives aux baux de locations -> en cas d'abandon du domicile ou de décès du titulaire du bail, le concubin peut faire continuer le contrat de bail à son profit si ce dernier vivait effectivement avec le preneur à bail depuis au moins un ans.

Il y a d'autres règles, 20 décembre 2007 : permet à un concubin de pouvoir représenter l'autre en justice (devant le tribunal judiciaire ou devant les prud'hommes).

=> Dans tous les cas, il faudra apporter la preuve de ce concubinage.

Aussi, les concubins n'ont aucune obligation financières l'un envers l'autre (pas de règles de solidarité etc)

Les concubins peuvent toutefois faire des acquisitions en commun, ainsi, ces biens tomberont dans l'indivision.

3/ La rupture du concubinage

Le concubinage est gouverné par un principe de liberté, il peut être rompu librement. Chaque concubin peut mettre fin à son union de façon unilatérale -> ad notum aucune formalité particulière et pas de motifs particuliers.

La rupture étant libre, le simple fait de le rompre n'ouvre en principe à aucune indemnité particulière ni compensation.

Mais comme en matière du pacs, en fonction des circonstances de rupture, le concubin délaissé pourra réclamer à l'auteur de la faute de possibles dommages et intérêts, dès lors qu'on arrive à caractériser un préjudice qui résulte de cette faute, (art 1240.)

Arret cour d'appel de Rouen 29 janvier 2003 : les juges de la CA on considéré comme fautif le concubin qui a abandonné sa compagne et leur enfants, brutalement, sans leur laisser d'argent, et ce alors même que la concubine ne bénéficiai pas de revenus, tout en prenant soin, avat de quitter le domicile de résilier les abonnements d'eau et d'électricité du domicile.

Arret CA de Paris en 2013 : situation similailre, du jour au lendemain le concubin à déménagé tous leur meubles sauf le berceau.

=> Mais n'a pas été jugé fautif le mutisme d'un concubin et les paroles blessantes accordées à sa concubine avant la séparation. Les juges ont dit que c'était pas un comportement fautif.

Partie 2 : Le droit de la famille relatif aux enfants

L'enfant est le reflet d'une place privilégiée dans le droit car personnes vulnérables, puisqu'ils représentent l'avenir de la famille mais aussi de la société. Le droit prend également en compte le fort désir qu'ont généralement les couples d'avoir des enfants, en réservant une place particulière à l'enfant dans le droit de la famille.

I – Les règles relatives à la filiation

La filiation se définit comme le lien de droit qui unit l'enfant à ses parents et ce lien est plus ou moins dépendant du lien biologique qui existe entre un parent et un enfant.

Le droit civil a beaucoup évolué ces dernières années (contentieux importants et évolutions de la société). Les traits marquants : le principe de vérité et le principe d'égalité.

– Le principe d'égalité : Aujourd'hui par exemple, on ne parle plus de filiation légitime et de filiation naturelle.

– Le principe de vérité : la vérité biologique, la matière est confrontée à l'émergence de nouvelles techniques de procréation (don de sperme, ovules, gamètes, etc), repose sur la volonté d'une filiation d'avantage sociale que biologique dont l'adoption est la plus classique.

Il existe 3 grands types distincts de filiation :

- La filiation par procréation naturelle
- La filiation par procréation médicalement assistée
- La filiation adoptive

A – La filiation par procréation naturelle

C'est le mode de filiation le plus commun avec le plus de règles et de contentieux.

Depuis le 4 juillet 2005, on ne parle plus de filiation naturelle qui renvoyait à une distinction d'enfant né durant le mariage et ceux hors mariage.

Aujourd'hui le Code Civil comprend dans son titre 7 relatif à la filiation plusieurs chapitres :

– Le premier chapitre porte sur les dispositions générales relatives à la filiation → règles qui fixent un principe d'égalité et d'interdiction de l'inceste. Dans les articles en questions, il est précisé que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont dans leur rapports avec leurs parents les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quelque soit la filiation, elle fait entrer l'enfant dans la famille. Seule exception, sur les règles relatives à l'adoption simple (elle ne romps pas totalement les liens de l'enfant avec sa famille biologique). Art 310-2, prévoit une règle qui interdit l'inceste s'il existe entre les parents un empêchement à mariage : si la filiation est déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit = la première filiation exclue l'autre.

Arrêt cour d'appel de Caen du 8 juin 2017 : maintient d'un double lien de filiation d'un enfant avec ses parents alors que normalement le lien n'aurait pas du être reconnu à l'égard du père puisque lien en ligne collatérale avec la mère.

Les juges ont considéré qu'au regard de l'intérêt particulier de l'enfant, et des conséquences dommageables qu'auraient pour lui dans la construction de son identité, l'annulation d'un lien de filiation sur lequel s'est construite jusqu'à présent sa place dans l'histoire familiale, il n'y a lieu de réformer le jugement.

- le deuxième sur les **modes d'établissement non contentieux de la filiation**
- le troisième sur **l'établissement contentieux** de celle ci,

1/ L'établissement non contentieux de la filiation

Les cas dans lequel le lien de filiation va être reconnu sans qu'il y ai besoin de passer devant un juge. Art 310-1 du CC, précise qu'il y a plusieurs mode d'établissement non contentieux du lien de filiation. Il explique que la filiation **peut être établie par les faits de la loi** (présomption de paternité), elle **peut être établie par la reconnaissance volontaire** (avant ou après la naissance), ou elle **peut être établie par un acte de notoriété** (règle de la possession d'état).

a) Etablissement de la filiation par l'effet de la loi :

- La filiation maternelle qui s'exprime par l'acte de naissance : En principe, à part les accouchement sous X, la **filiation maternelle est une filiation par le fait de la loi art 311-25** « la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »

L'acte de naissance est censé faire foi de l'accouchement de la mère, de la date et du lieu de naissance de l'enfant. Il est dressé par l'officier d'Etat civil par le père ou a défaut par le personnel médical. Il faut donc un certificat médical d'accouchement délivré par l'hôpital afin d'éviter les fausses déclarations.

-> **Accouchement sous X** si la mère veut garder le secret ou, avant 2 mois, ouvrir le secret – Loi du 22 janvier 2002 : **aménagement d'un mécanisme de réversibilité du secret**. La mère de naissance est invitée à laisser des informations destinée à l'enfant (identité etc), si elle laisse ces infos, ces renseignements vont être conservées par le Conseil National pour l'accès aux origines personnelles. Les enfants vont pouvoir les consulter mais deux conditions : **faire la demande + la mère de naissance donne son accord**. Mais attention, ces infos n'auront aucun effets sur l'état civil de l'enfant ni sur sa filiation. **Art L147-7 du code de l'action sociale et de familles** qui précise que l'accès d'une personne à ses origines est sans effets sur l'état civil et la filiation, et ne fait naître ni droits ni obligations au profit ou à la charge de qui que ce soit. Que ce passe t'il si elle la mère de naissance est décédée et qu'elle n'a pas exprimé son refus de son vivant : dans ce cas là, l'identité peut quand même être révélée à l'enfant.

- La filiation paternelle par la présomption de paternité : le législateur fixe une présomption de paternité. La présomption est un **mécanisme juridique qui permet de déduire d'un fait connu, facile à prouver, un fait inconnu difficile à prouver en raison de ce fait connu**. Cette filiation paternelle est établie grâce à une présomption qui joue au bénéfice du mari qui à épousé la mère de l'enfant. Cette présomption est prévu à **l'art 312 du CC** « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». (car obligation de fidélité dans le mariage) -> il faut donc que le mariage est eu lieu avant la conception de l'enfant = **présomption de conception (infans conceptus)**

Fixé **art 311 du CC**, pour s'assurer que l'enfant a bien été conçu pendant le mariage il faut

que le couple est été marié entre le 300e jours avant la naissance et le 180e jour avant la naissance. Si le couple était déjà marié, on va présumer que l'enfant a été conçu pendant le mariage, et donc la présomption de paternité va bénéficier au mari.

Toutefois, la **présomption de paternité est une présomption simple** (depuis 2009), c'est à dire, à la différence des **présomptions irréfragables** sont des présomptions contre lesquelles **ont peut apporter une preuve contraire, démontrer que la présomption est fausse.**

On peut contester la présomption de paternité dans le cadre d'une **action en contestation**, par le biais d'une expertise par exemple.

La **présomption de paternité peut également être écartée dans 2 situations :**

– **L'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari** en qualité de père de celui-ci. Lorsque l'enfant est né alors que **les époux étaient séparé de faits.**

– **Les époux sont en cours de divorce** : depuis 2020 le CC prévoit que **si l'enfant né plus de 300 jours après l'introduction de la demande en divorce ou après le dépôt au rang des minutes d'une convention de divorce, la présomption ne peut jouer à l'égard du mari.**

Néanmoins il **existe toutefois 2 possibilités de rétablir cette présomption** de paternité alors qu'elle a été écarté.

– **Art 314 CC** : le mari à la possession d'état de père à l'égard de l'enfant. (voir suite du cours)

– **Art 315 CC** : le mari intente une action judiciaire en rétablissement de la présomption de paternité

Dans tous les cas, le mari qui ne bénéficiera pas de cette présomption a toujours la possibilité de reconnaître l'enfant (a condition qu'il n'a pas déjà été reconnu par un tiers)

b) Etablissement de la filiation par la reconnaissance volontaire

Art 316 du CC qui précise « **lorsque la filiation est pas établie par les faits de la loi, elle peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de maternité qui peut être faite soit avant soit après la naissance.** »

Cette reconnaissance est un **acte de volonté par lequel l'auteur de la reconnaissance affirme être le père ou la mère de l'enfant.** Cette acte de reconnaissance a un effet puissant, il **va rattacher l'enfant à l'auteur de cette reconnaissance et va créer entre-eux un lien de filiation.**

→ Cette **reconnaissance est différente de la déclaration de naissance.**

La reconnaissance est un **acte réalisé en plus de la déclaration et est nécessaire pour établir la relation entre l'enfant et l'auteur de l'acte.**

La reconnaissance de l'enfant ne **va donc concerner que les pères non mariés et les mères qui ont accouchées sous X** mais qui souhaiteraient finalement revenir sur leur décision et établir la filiation avec l'enfant.

– **Les conditions de fond** : il est **impossible de reconnaître un enfant dont le lien de filiation est déjà établie** à l'égard de quelqu'un d'autre.

Pour ce faire, il faudra d'abord **contester en justice la filiation** qui a été établie pour demander **l'anéantissement**, et une fois anéantie, on peut demander à reconnaître l'enfant.

A contrario, il est **possible de reconnaître n'importe quel enfant dont la filiation n'est pas déjà établie**. C'est un **acte personnel facultatif**. On ne peut pas obliger une personne à reconnaître un enfant. De la même manière, il n'a besoin d'aucune autorisation préalable pour le reconnaître.

– **Les conditions de formes** : En raison de la **gravité et de l'importance de l'acte** cette **reconnaissance va exiger une forme spécifique** : **acte authentique dressé par un officier d'Etat civil ou un notaire, à peine de nullité**. Dans cet acte vont devoir être mentionnés des conditions **art 62 CC**, encore à peine de nullité.

La reconnaissance **n'est soumise à aucun délai et peut intervenir n'importe quand**.

– **Les effets** : l'acte de reconnaissance permet **d'établir la paternité ou la maternité de son auteur, un lien de filiation se crée entre l'adulte qui reconnaît l'enfant et ce dernier**. Cette reconnaissance est **irrévocable**, on ne peut pas se rétracter.

Dans les faits, il est apparu plusieurs **abus de cette reconnaissance**, et est apparu des **reconnaisances de complaisances**.

→ Reconnaissances d'enfants faites par des hommes qui savent pertinemment ne pas être le père biologique de l'enfant, dans le but de bénéficier de certains avantages, facilités en matière de séjours et d'acquisition de la nationalité française.

Pendant longtemps ces reconnaissances de complaisance étaient tolérées par le législateurs. Par la **loi de septembre 2018**, le législateur a instauré dans **l'art 316**, des **vérifications a priori pour identifier l'auteur de la reconnaissance** (justification de son identité véritable, de son domicile et résidence).

→ 4 articles ont été insérés à la suite du 316, qui prévoient que **l'officier EC ou le notaire qui suspecteraient une reconnaissance frauduleuse ont la possibilité de saisir le Procureur de la République**, qui pourra soit laisser l'OFC enregistrer la reconnaissance, soit suspendre la procédure, soit faire opposition à la reconnaissance.

c) Etablissement du lien de filiation par la possession d'état

Cette possession d'état renvoie à un principe plus général en droit, la possession.

La **possession d'état se définit en droit de la famille comme un mode d'établissement de la filiation qui repose sur la prise en considération des faits**. Pour cette raison, il s'agit également d'une présomption. En raison de l'existence d'une relation affective entre un enfant et une adulte, (fait facile à prouver), on suppose l'existence d'un fait inconnu, que cet adulte est bien le parent biologique de l'enfant. Ce **mode d'établissement de la filiation est prévu à l'art 317**. Il ne sera **employé que dans le cas où les autres modes d'établissement auront échoués**.

Il ne sera employé que dans des **situations anormales** (situations dans lesquelles l'enfant n'aurait pas été reconnu par l'un de ses parents ou n'a pas bénéficié de la présomption de paternité.)

Par exemple, ce mode a un intérêt pour un enfant, au moment du décès d'un adulte, qui se serait occupé de lui pendant toute sa minorité, mais dont il **n'y a pas d'acte de reconnaissance ni de présomption de paternité**.

L'enfant pourra se prévaloir de cette possession d'état -> il pourra récupérer l'héritage... Mais ce n'est pas si simple. Le droit fixe un certain nombre de conditions : **va falloir prouver l'existence de cette possession d'état et arriver à démontrer l'existence de caractéristiques particulières.** Art 311-1 du CC : la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits, qui révèlent le lien de filiation et de parenté, entre une personne et une famille à laquelle elle est dite appartenir.

Le droit, à travers cet article, va **prendre en compte l'existence d'une réalité sociale affective.** Pour ces raisons, la possession d'état, pour être prouvée, va devoir réunir des éléments qui sont généralement rangés en 3 catégories :

- **Tractatus** -> renvoie au terme de traitement, il faut rapporter la preuve que les **intéressés se soient réciproquement traités et reconnus en parents et enfants.** (par exemple : l'adulte a pourvu à l'éducation, à l'entretien moral et matériel de l'enfant) => élément le plus déterminant car témoigne d'une réalité familiale

- **Nomen** -> Renvoie au nom, c'est le fait que **l'enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu** => élément le moins important, il peut **ne pas être pris en compte.**

- **Fama** -> La réputation, la renommée. Fait de **rapporter la preuve que l'enfant est reconnu comme étant l'enfant de l'adulte en société** (famille, entourage, amis) les tiers, de manière générale, reconnaissent qu'il existe un lien de parenté entre l'adulte et l'enfant.

=> **Ces faits ne sont pas cumulatifs**, même si on ne rapporte que le tractatus cela peut suffire aux juges pour constater une possession d'état.

Parfois, on peut rapporter la preuve du tractatus et celle du nomen, tandis que la preuve du fama faire défaut, peut remettre en cause les autres preuves.

-> **Question de savoir si on peut reconnaître la possession d'état à l'égard du concubin de même sexe du parent de l'enfant.**

La Cour de cassation, par un avis du 7 mars 2018, répond par la négative en expliquant que la possession d'état vise à tirer d'un fait connu un fait inconnu (l'existence d'un lien de filiation biologique), or on ne peut pas tirer la conséquence qu'il existe un lien biologique entre les deux individus.

=> Cette jurisprudence peut être amenée à évoluer.

Une fois la **possession d'état prouvée, pour qu'elle puisse permettre de créer un lien de filiation juridique, il faut que cette possession d'état remplisse un certains nombres de critères** prévu à **l'art 311-2 du CC** : pour produire des effets de droit, la possession d'état doit être également **continue, paisible, publique et non équivoque.** -> ces **caractères sont cumulatifs, il faut avoir les 4.**

- **Continuité** : cela renvoie à la notion de durée, elle **doit être stable sur une longue durée.** Des rapports sociaux affectifs brefs ne pourraient suffire -> **attitude constante et assidue.**

Cette possession d'état s'établit sur le long terme, avec le temps.

Jurisprudence : n'exige pas que la possession d'état ait nécessairement commencée dès la naissance de l'enfant.

- **Paisibilité** : pendant toute la durée de la relation de fait, **ne doit exister aucune action visant à empêcher ou contester le déroulement d'une vie de famille apparente entre les intéressés**. On ne pourra jamais reconnaître une possession d'état paisible à l'égard d'un individu qui aurait enlevé un enfant.
- **Publicité** : cette **relation socio-affective doit être connue de tous**. Par exemple, le cas où le parent reste caché, refuse de reconnaître l'enfant en public.
- **Non-équivoque** : Renvoie au fait que, à l'égard de tous et à l'égard des personnes concernées elles-mêmes, **le lien entre la mère ou le père et l'enfant doit être exclusif**. → cas où deux pères reconnaissent la possession d'état.

Jurisprudence :

On retrouve de nombreuses situations dans lesquelles les juges vont reconnaître une possession d'état :

Arrêt 11 fev 2009 cour de cass : reconnaissance d'une possession d'état à l'égard d'un père qui a assumé sa paternité alors même qu'il ne bénéficiait pas de la présomption et qui versait une pension alimentaire etc, et les grands parents s'occupaient également de l'enfant.

Arrêt 24 juin 2023 : un homme se présentait comme le père de l'enfant et a contribué à l'éducation etc jusqu'à ses 18 ans, et a entretenu avec lui un lien régulier, les juges ont reconnu la possession d'état.

La possession d'état est un fait socio-affectif dont on déduit le lien de filiation. **La preuve de cette possession d'état est libre, peut être apportée par tous les moyens**.

Si le juge peut être amené à se prononcer concernant l'existence ou non de la possession d'état, **l'établissement du lien de filiation par possession d'état n'est pas forcément judiciaire**. Dans ce cas là, elle prend une forme particulière. Autrement dit, pour produire des effets sur la filiation, **la possession d'état doit être constatée par un acte public**. → par un acte dit de notoriété.

Un acte de notoriété est un **acte qui est demandé au notaire par le parent ou l'enfant qui entend s'en prévaloir, et vont alors devoir attester de la réalité de la situation affective alléguée, en fournissant 3 attestations de témoins qui vont dans ce sens**.

Ces témoignages vont devoir permettre de constater l'existence du tractatus, du nomen et du fama, ainsi que les critères de continuité, publicité, paisibilité et non-équivoque.

Une fois délivré, **l'acte de notoriété va permettre d'en faire mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, permettant ainsi d'établir le lien de filiation**.

La demande en délivrance de l'acte de notoriété ne peut se faire que dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée, ou à compter du décès du parent prétendu.

La possession peut aussi être constatée par jugement, par un tribunal, dans le cadre d'une action en contestation de la possession d'état.

2/ L'établissement contentieux du lien de filiation

Cet **établissement du lien de filiation** est l'**objet de contentieux abondant**. Un enfant peut vouloir contester la filiation à l'égard de son parent, un parent peut vouloir faire établir un lien de filiation à l'égard d'un enfant.

Il peut y avoir contentieux quand un lien de filiation est déjà établi à l'égard d'un autre, ou lorsque un individu voudra faire établir un lien de force avec son parent.

Il y a **deux contentieux distincts de la filiation** :

- des actions en recherche de filiation / de paternité / maternité
- des actions en contestation du lien de filiation

a) Les actions en recherche de filiation

Renvoient au **contentieux relatif à l'établissement de la filiation**. L'**art 310-1°2** indique que la **filiation peut être établie par jugement**. On parle d'établissement contentieux ou judiciaire de la filiation.

– **Les règles procédurales communes** : qu'il s'agissent de recherche en paternité / maternité, **l'action est toujours réservée à l'enfant** (même si pendant sa minorité l'action devra être menée en son nom, soit par le parent déjà établi ou par son tuteur). Malgré cela, l'enfant peut-il agir indéfiniment ? Non, **l'action est enfermée dans un délai de 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame** (en gros la naissance). Mais ces 10 ans, en réalité, ne **démarrent qu'à partir de la majorité de l'enfant**. (donc 18 ans)

Cette action va nécessiter de **rapporter la preuve du lien de filiation biologique**. → La preuve de ce fait est libre et peut être rapportée par tout moyen.

Preuve reine : la preuve que l'on recherche toujours car permet d'établir ce lien de manière quasi certaine = la **preuve biologique, le test**

→ Cependant il y a le **principe de l'inviolabilité de la personne**, puisque cet acte est un acte invasif, qui, si elle n'est pas consentante, va porter atteinte à son intégrité.

Le code civil va prévoir un **régime particulier pour apporter cette preuve**, **art 16-11** : en matière civile, **l'identification biologique ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure ordonnée par un juge saisie d'une action en contestation du lien de filiation**, le **consentement de l'intéressé préalablement et expressément recueilli**, sinon, aucune empreinte biologique etc ne peuvent être réalisées après sa mort.

CM11 : 3/04/2025

– **L'action en recherche de maternité :**

Art 325 du CC : l'action en **recherche de maternité est réservée à l'enfant**, qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

En droit français la filiation maternelle va dépendre de l'accouchement. L'action en recherche de maternité est donc une action très compliquée. → si le lien de filiation n'est pas établi c'est parce que la mère a accouché sous X. Ainsi, l'enfant ne sait pas vers qui faire la démarche.

Si, malgré tout il parvient à identifier sa mère biologique, **il faut que l'enfant n'ai titre ni possession d'état à l'égard d'une autre mère.**

La preuve que la mère est bien sa mère biologique est là aussi difficile à apporter, il est possible de faire un test biologique avec le consentement de la mère.

- L'action en recherche de paternité :

Résulte de **l'art 327 du CC** : **la paternité hors mariage peut être judiciairement déclaré.** Le juge va pouvoir déclarer un lien de filiation unissant un enfant à son père.

Est-ce que tout le monde peut faire une action en recherche de paternité ?

Il y a un certain nombre de conditions :

- Limites liées à une filiation déjà établie. Si un enfant a déjà un lien de filiation, il ne pourra pas mener immédiatement une recherche en filiation. **L'enfant va devoir contester la filiation paternelle prèe établie**, et ce n'est que s'il obtient gain de cause (dissolution du lien de filiation), qu'il pourra ensuite agir en action de recherche de paternité.

- De la même manière, cette action est enfermée dans un certain délai. **Elle ne peut s'exercer que pendant 10 ans, à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame** (la naissance), mais toutefois la **minorité suspend le délai de prescription** (démontre à la majorité).

Que se passe-t-il si le tribunal considère que cette personne est bien le père bio de l'enfant, dans ce cas là, le prononcé de la **décision de filiation sera établie de façon rétroactive** → l'enfant est bien celui du père et ce depuis le jour de sa naissance.

Conséquences : si ce monsieur est bien le père depuis la naissance, **l'ensemble de ses devoirs à l'égard de l'enfant lui sont dus.**

- L'action en constatation de la possession d'état :

Pour **reconnaitre la possession d'état il faut établir un acte de notoriété.** Une fois établi, cet acte permet d'établir le lien de filiation entre l'enfant et le parent. Cet acte est un **acte authentique qui ne peut être réalisé que si les personnes concernées sont d'accord.** En cas de conflits, ou en cas d'impossibilité d'établir cette possession d'état par acte de notoriété, il sera toujours **possible d'agir en justice afin de faire constater cette possession d'état.**

Art 330 CC : « la possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai de 10 ans à compter de cette cessation ou du décès du parent prétendu. »

Cette action judiciaire se distingue de l'acte de notoriété puisqu'il nécessite de saisir une juridiction, mais surtout **toute personne qui y a intérêt peut faire constater cette possession d'état**, alors que l'acte de notoriété n'était réservé qu'à l'enfant et au parent.

De plus, à la différence de l'acte de notoriété où il suffit de témoignage, ici il **suffit de convaincre le juge de cette possession d'état avec des éléments qui le démontre** (tractus, fama, nomen, paisible, non équivoque etc.).

Si on arrive à convaincre le juge, ce dernier va, par sa décision, établir le lien de filiation entre le parent et l'enfant.

Ce lien établi judiciairement est important car la possession d'état ainsi établie devient incontestable (le lien de filiation devient fixe, figé, car il est le résultat d'une décision de l'autorité judiciaire, et prend donc **valeur de chose jugée**)

b) Action en contestation du lien de filiation

On va vouloir **remettre en cause une filiation déjà établie**. On va retrouver 3 actions possibles en contestation du lien de filiation.

- Art 332°1 : Action en contestation de la filiation maternelle
- Art 332°2 : action en contestation de filiation paternelle
- Art 335 : Action en contestation de la filiation établie par possession d'état (non contentieux)

- Le régime juridique des actions en contestation du lien de filiation :

Ce régime juridique qui prévoit les délais de prescriptions et les qualités pour agir vont varier en fonction de la façon dont la filiation qui est contestée a été établie, mais également de l'existence ou non, d'une possession d'état.

3 situations :

° L'enfant dispose d'un titre nu : un titre de naissance qui établit la filiation que l'on souhaite contester, sans que ce titre ne soit conforté par une possession d'état qui lui correspond (le père qui l'a reconnu ne s'est pas occupé de lui).

→ Art 334 CC : l'action en contestation du lien de filiation est ouverte largement à toute personne qui y a intérêt (père, mère, l'enfant, le parent prétendu, les demi frères et demi sœur) dans un délai de 10 ans à compter de la naissance (+ majorité), ou à partir de la reconnaissance de cet enfant si elle a eu lieu ultérieurement.

° L'enfant dispose d'un titre et d'une possession d'état conforme à ce titre : Par exemple un enfant qui est reconnu à sa naissance ou résomption de paternité et qui est élevé par la personne. Le fait que le titre soit conforme à la possession d'état laisse supposer que le rattachement juridique de l'enfant à ce parent correspond à la vérité biologique. Un tel lien ne peut être remis en cause qu'avec prudence.

→ Art 333 CC : l'action en contestation n'appartient qu'à l'enfant, ses père et mère, ou à celui qui se prétend être le parent véritable. Le ministère public peut lui aussi contester. On dit que c'est une action attitrée (avoir un titre pour agir). Par ailleurs, le délai est en fait plus restreint : 5 ans pour agir (à partir de la majorité). Si jamais la possession d'état conforme au titre que l'on constate a duré au moins 5 ans depuis le moment de la reconnaissance, il sera alors impossible d'agir en contestation de ce lien. La seule personne qui peut agir dans un délai de 10 ans est le ministère public → il peut contester les filiations établies lorsque ces filiations laissent supposer une fraude à la loi, en particulier dans les cas d'établissement du lien de filiation à la suite de GPA à l'étranger, qui constitue des fraudes à la loi.

° Possession d'état entre le parent et l'enfant mais pas de titre :

→ Art 335 : La contestation est alors possible pour toute personne intéressée dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété. Il faudra alors

la preuve au juge que la possession d'état n'est pas légale (pas paisible ou pas public etc).

- Les effets de la contestation de la filiation :

Si la demande est accueillie par le juge, la **principale incidence de cette action est l'anéantissement du lien juridique de filiation**, celui qui, jusqu'à présent était juridiquement désigné comme le parents de l'enfant ne l'est plus.

Cela va produire des **effets qui sont de nature rétroactive**.

-> L'enfant ne sera **plus à même de porter le nom du parent** (sauf pour les enfants devenus majeurs, la modification du nom sera faite avec son consentement).

-> Si l'enfant est mineur, le **parent de l'enfant perd tout ses droits et prérogatives** (autorité parentale, administration etc), celui qui perd la qualité de parent **n'est plus tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant**. (il va être possible de demander le remboursement de l'argent versé au cours de la filiation).

=> Toutefois **si le lien ainsi rompu avait été établi par une reconnaissance de complaisance, la jurisprudence va considérer que cette personne ne pourra pas réclamer le remboursement** des sommes versées puisqu'il savait très bien qu'il n'était pas le père et n'était pas obligé de lui verser de l'argent, il a fait des dons.

Le législateur n'est pas resté insensible au sort de celui qui était considéré comme le parent et du jour au lendemain n'est plus considéré comme tel. Le **législateur a pris compte de la réalité affective qui a pu se nouer entre le parent et l'enfant, le Code Civil prévoit une sorte de consolation à l'égard du parent qui ne l'est plus : art 337 du CC**, permet au juge, lorsque la **situation le nécessite, dans l'intérêt de l'enfant**, de pouvoir organiser, malgré la dissolution rétroactive du lien, un **certain nombre de modalités pour permettre à ces relations de continuer**. Par exemple, en accordant à ce parent un droit de visite, dans la mesure où il en va de l'intérêt de l'enfant.

Il **peut exister des actions en responsabilités qui résultent de ces actions en contestation du lien de filiation**. => si le lien de filiation a faussement perduré en raison de la faute de la mère, il est possible de demander réparation.

Arret 30 juillet 2014 CA Grenoble : une femme qui avait fait croire à l'homme avec qui elle vivait que son enfant était le sien, le jour de la naissance il l'a reconnue. La mère, 4 ans après, engage une action en contestation en paternité, le dossier met en évidence qu'elle fait croire à cet homme qu'il était le père biologique, les magistrats ont déterminé que ce comportement était fautif -> engage des dommages et intérêts art 1240

B – La filiation adoptive

L'adoption crée un lien de filiation entre des personnes qui n'ont pas de lien biologique. Cette filiation ne peut être **prononcée que judiciairement**.

On distingue deux types d'adoption qui vont avoir des effets différents selon le degré d'intégration que l'adopté possède dans sa nouvelle famille.

- **L'adoption plénière** : Le lien de **filiation premier** qui unit l'enfant à son parent biologique est **totalement anéanti et est remplacé par le nouveau lien de filiation avec la famille adoptive**.

– L'adoption simple : Le lien de filiation nouveau créé à l'issue de la procédure va s'ajouter aux liens de filiations préexistants. L'enfant est rattaché aux deux familles.

Ce droit de l'adoption a fait l'objet de bouleversements récents → **Reforme 21 février 2022**, l'adoption est ouverte aux couples non mariés, alors qu'elle ne bénéficiait jusque là qu'aux couples mariés et aux célibataires.

Art 343 et suiv du CC ne visent que les adoptions réalisées sur le territoire national. Malgré tout, un grand nombre d'adoption ont lieu à l'international. Ces adoptions vont devoir répondre aux règles du pays de l'enfant adopté.

1/ Les conditions similaires des adoptions

→ **Art 343** l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps (communauté de toit), aux partenaires liés par un PACS, ou par deux concubins, à condition que les adoptants soient en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie, d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans.

→ **Art 343-1 du CC** : explique que l'adoption peut aussi être demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans (célibataire) ou une personne en couple mais qui décide d'adopter seul un enfant. Si l'adoptant est marié ou PACS le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire.

Cette situation, en réalité, est assez courante, lorsque le conjoint de la mère adopte l'enfant de celui-ci. Dans ce cas-là, la condition d'âge n'est pas requise.

→ **Art 347 du CC** : il existe une condition qui va imposer un âge de différence minimum entre l'adoptant et l'adopté. (minimum 15 d'écart avec l'enfant). Toutefois, cette règle est susceptible de faire l'objet d'une exception lorsqu'il existe des motifs justes (appréciation du juge). Cette différence d'âge de 15 ans est limitée à 10 ans lorsque l'adoption vise l'enfant de l'autre membre du couple.

Il existe des prohibitions à l'adoption :

→ **Art 346** : Prohibe l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœur, sauf exceptions.

→ **Art 344 CC** : liste des enfants qui peuvent, en raison d'une certaine qualité, être adoptés. (Tous ceux non cités ne pourront pas.)

- Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption
- Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil des pupilles a consenti à l'adoption
- Les enfants judiciairement déclarés délaissés
- Les majeurs en adoption simple (exception art 345)

1. L'adoptant :

Lorsque les adoptants ont eux-même déjà des enfants, ces derniers n'auront pas à consentir à l'adoption ni à s'y opposer, Art 353-1 du CC. Mais malgré cette absence de consentement, il faut préciser que le tribunal en charge de la procédure d'adoption devra vérifier que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale de l'adoptant et de ses descendants.

Cependant, en ce qui concerne les adoptants, eux doivent exprimer un consentement libre et éclairé (le tribunal doit s'assurer que l'adoptant est bien conscient des conséquences d'une adoption). Pour s'assurer de cela, le CC prévoit que le consentement doit être donné devant un notaire ou, s'il est fait à l'étranger, dans un consulat ou ambassade française. Ce consentement peut aussi être reçu par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Ainsi, l'adoptant dispose d'un droit de rétractation. Art 348-5 CC, l'adoptant peut rétracter son consentement pendant 2 mois (pendant la procédure).

2. L'adopté :

Le droit prévoit deux situations en fonction du discernement de l'adopté. Art 349 al 1 dispose que l'adopté âgé de plus de 13 ans consent personnellement à son adoption. Cependant, avant 13 ans, le tribunal pourra entendre l'enfant, mais ce n'est pas une condition de validité du prononcé de l'adoption (par exemple, même si l'enfant refuse l'adoption, le juge peut tout de même la prononcer s'il en va de l'intérêt de l'enfant).

Mais, que l'adoption soit plénière ou simple, le juge qui la prononce devra toujours prendre en compte l'art 350 du CC → doit s'assurer que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté. Il existe là encore un délais de rétractation, et ce, à n'importe quel moment de la procédure, même au moment du prononcé de la décision.

a) Les spécificités de l'adoption plénière

L'adoption plénière est une technique d'adoption qui permet d'assimiler totalement l'enfant adopté à la famille du parent adoptif. C'est pour cette raison, que en principe, cette adoption n'est permise qu'aux enfant de moins de 15 ans, et qui sont accueillis au sein du foyer des adoptants depuis au moins 6 mois (à la suite d'une procédure de placement par exemple). Cette procédure est également ouverte jusqu'aux 21 ans de l'adopté mais dans certaines circonstances :

- si celui ci à été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas dans le délais voulu les conditions légales pour adopter.
- l'adopté a fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans par les mêmes adoptants.
- l'enfant en question est pupille de l'Etat
- l'enfant est déclaré judiciairement délaissé
- l'enfant adopté est l'enfant biologique de l'autre membre du couple

Lorsque l'enfant adopté n'est pas l'enfant du conjoint, l'adoption plénière ne peut se réaliser qu'après le placement d'au moins 6 mois de l'adopté auprès du parent qui souhaite l'adopter (art 351 CC).

Il va donc y avoir une procédure de placement de cet enfant auprès de la famille qui souhaite l'adopter.

Ce placement a un **effet juridique extrêmement important** : il va permettre de prononcer l'adoption après un délais de 6 mois, et il va **interdire toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine**. Cette procédure de placement est un réel contentieux, notamment dans les situations d'accouchement sous X lorsque le père biologique souhaite par la suite reconnaître l'enfant.

Arrêt 11 septembre 2024, un père entame des démarches pour retrouver son enfant né sous X, et qui a été par la suite admis comme pupille de l'Etat. Problème, à la suite de l'accouchement, la mère a fait croire au père que l'enfant été décédé. Mais le père est parvenu à identifier l'enfant et a souhaité le reconnaître. Mais cette reconnaissance est intervenue à la suite du placement de l'enfant dans une famille. Lors du prononcé de l'adoption, le père a agi en intervention forcée pour faire valoir ses droits. Les juges ont décidé que l'intervention du père est irrecevable pour défaut de qualité à agir, puisqu'il agissait pendant le placement de l'enfant, qui fait obstacle à la restitution. => La Cour de Cassation va répondre en vérifiant par le contrôle de constitutionnalité (CEDH), la Cour de Cassation va à nouveau rejeter la demande en reprenant à son compte la motivation de la cour d'appel. Pour s'assurer que cette décision ne porte pas atteinte à la vie privée du père, la Cour de Cass ajoute que cette décision se fonde sur des règles qui permettent de préserver l'intérêt de l'enfant et qui poursuivent des buts légitimes, visant à protéger les droits d'autrui, d'une part en évitant les conflits de filiation, et d'autre part en sécurisant, dans l'intérêt de l'enfant et des adoptants eux-mêmes, la situation de filiation de celui-ci à compter de son placement. La Cour va estimer que l'atteinte à la vie privée et familiale du père est légitime et mesurée, puisque malgré le fait qu'il ne sera pas reconnu comme le père, le droit prévoit un certains nombre de procédures qui permettent aux parents biologiques de retrouver leurs enfants avant la procédure de placement. (Saisie du Procureur de la République pour retrouver l'enfant avant que le placement n'est lieu.) De plus, la Cour considère que l'ensemble des dispositions qui permettent au père biologique de réagir afin de trouver un équilibre entre son intérêt et celui de l'enfant. => le parent pourra demander un droit de visite, même après une adoption plénière.

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui **se substitue à sa filiation d'origine, sauf dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint**. Dans ce cas, l'adoption laisse subsister la filiation d'origine avec la famille du conjoint.

De plus, l'adoption plénière **confère le nom de l'adoptant**.

Et, **art 359 CC**, une fois prononcée, l'adoption plénière devient irrévocable, et ses effets sont rétroactifs, et remontent au jour du dépôt de la requête en adoption.

b) Les conditions d'adoption simple

Les conditions sont moins rigoureuses que l'adoption plénière, il **n'y a pas de conditions d'âge**, **art 345-1**.

Toutefois, les **conditions relatives à l'âge de l'adoptant / la communauté de vie etc sont toujours exigés**.

Aussi, si **l'adopté à plus de 13 ans, son consentement est requis**. Cependant la condition de placement préalable n'existe pas, sauf si l'enfant est déclaré judiciairement délaissé, ou

lorsque c'est une pupille de l'Etat.

De plus, la condition liée à l'intérêt de l'adopté demeure primordial, mais étant donné que l'on a souvent affaire à des adoptés majeurs, le juge sera moins regardant sur son intérêt.

Art 360 du CC, l'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et va y conserver tous ses droits. L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits de l'autorité parentale.

Certes l'enfant garde ses droits avec la famille d'origine, mais l'autorité parentale est confirmée au parent adoptant. Mais, exception, le parent adoptant partage l'autorité parentale avec le parent de la famille d'origine lorsque l'enfant adopté est celui du conjoint.

Concernant le nom, celui de l'adoptant va s'ajouter à celui de l'adopté, mais s'il a plus de 13 ans il devra donner son accord à cet ajout.

De plus, l'adoption simple est révocable. L'adoptant comme l'adopté vont pouvoir agir en justice pour demander la révocation, à condition que la demande soit justifiée par des motifs graves. Toutefois, lorsque l'enfant est mineur, la révocation ne pourra être demandée que par le ministère public.

Aussi, la révocation n'a un effet que pour l'avenir.

FIN